

제4절 저당권이 있는 채권의 압류

I. 서

저당권이 있는 채권을 압류할 경우에 채권자는 채권압류의 사실을 등기기록에 기입하여 줄 것을 법원사무관등에게 신청할 수 있다. 이 신청은 채무자의 승낙 없이 법원에 대한 압류명령의 신청과 함께 할 수 있다(민집 제228조 제1항).

저당권의 피담보채권이 압류되면 담보권의 수반성에 의하여 종된 권리인 저당권에도 압류의 효력이 미치는데, 이 경우 채권의 압류를 공시하기 위해서는 등기기록에 그 사실이 기입되어야 한다. 또 압류사실을 등기기록에 기입함으로써 압류채권자의 저당권 실행을 쉽게 하는 의미도 있다.⁴¹¹⁾

II. 저당권부채권 압류의 효력

1. 압류와 본조에 의한 등기의 관계

가. 본조가 등기된 저당권에 의해 담보된 채권이 압류된 경우에 압류채권자의 신청에 의해 그 채권에 대하여 압류가 된 뜻의 등기를 촉탁해야 한다고 규정하고 있는 것은 다음과 같은 이유 때문이다.

즉 저당권 등 담보권은 금전채권을 담보하는 그 존재목적에 의해 규정되고, 그 통유성(通有性)으로서 채권의 이전에 따라 이전되며 또 채권과 함께 부담에 복종하는 성질[이른바 수반성(隨伴性)]을 가지므로 그 피담보채권이 압류되면 그 압류의 효력(처분제한효)이 종된 권리인 저당권에도 미치게 된다(민법 제361조 참조).

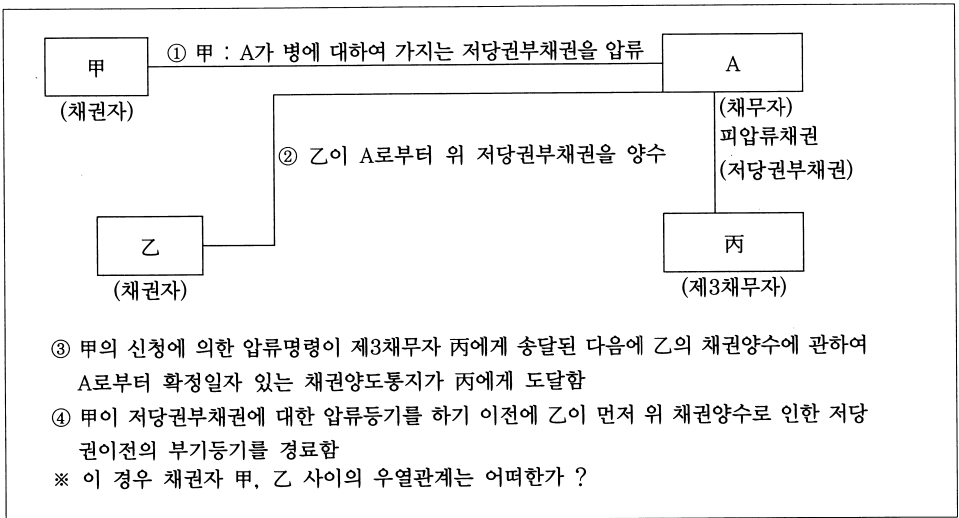
그러나 압류명령이 제3채무자에게 송달되어질 뿐인 상황에서서는 등기된 담보목적재산에 대하여 이해관계를 가진 제3자가 당해 저당권에도 압류의 효력이 미치고 있음을 알 수 없으므로 당해 저당권에도 압류의 효력이 미치고 있는 것을 이와 같은 제

411) 민사집행법 제228조는 저당권이 등기된 경우에 관하여만 규정하고 있으나, 광업권의 저당(광업법 제38조), 항공기의 저당(항공기저당법 제5조), 자동차의 저당(자동차저당법 제4조), 건설기계의 저당(건설기계저당법 제5조), 댐사용권의 저당(댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제32조) 등과 같이 등록에 의하여 저당권이 설정되는 경우에도 준용된다.

3자에게 대항하기 위해서 압류채권자는 이 점에 대하여도 대항요건을 구비해 둘 필요가 있다. 그래서 이와 같은 제3자와 저당권부채권의 압류채권자와의 대항관계상 이해의 조정을 위해 피담보채권이 압류된 뜻의 등기를 촉탁하는 방법을 마련하여 담보목적재산에 관한 거래의 안전을 도모하고 있는 것이다.

이와 같이 본조의 등기촉탁은 압류의 효력이 미치는 저당권에 대해 이해관계를 가지는 제3자와 압류채권의 대항관계상의 조정조치라고 보아야 하므로 예컨대 압류의 효력이 등기된 저당권에 미치고 있는 것이 명확한 경우라도 직권으로 본조에 의한 등기촉탁을 하는 것은 가능하지 않고, 피담보채권에 대해 압류가 된 뜻의 등기를 하는가 어떤가는 당해 압류채권자의 의사에 달려 있는 것이며,⁴¹²⁾ 그 등기촉탁을 신청하지 않은 것에 의한 불이익은 압류채권자가 부담할 수밖에 없다.⁴¹³⁾

나. 여기서 한 가지 주의할 것은, 저당권부채권에 대하여 채권압류와 채권양도가 경합된 경우, 압류에 수반하는 저당권에 대한 처분제한과 채권양도에 수반하는 저당권의 이전의 우열관계에 관한 것이다. 아래 사례를 보기로 한다.



위 사안은, 채권자 甲은 채무자의 저당권부채권을 먼저 압류하고 이에 대한 효력발생을 위한 압류명령의 제3채무자에 대한 송달도 채권자 乙의 채권양도에 관한 대항요건 이전에 되었지만, 채권자 乙이 甲의 압류등기 이전에 저당권이전의 부기등기를 해버린 경우에 관한 것인데, 이러한 경우에 甲, 乙 사이의 우열관계는 무엇을 표

412) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 334.

413) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 465.

준으로 해야 하는 것일까.

결론적으로 위 사안에서는 채권자 甲의 압류가 우선하게 된다. 즉 저당권부채권의 압류에 수반하는 저당권에 대하여 그 뜻의 등기가 되어도 저당권부채권의 압류채권자와 채권양수인과의 우열은, 당해 압류명령의 제3채무자에 대한 송달과 채권양도의 대항요건의 구비시기의 선후에 의해 결정되는 것이고, 피담보채권에 대하여 압류가 된 뜻의 등기와 채권양도에 의한 저당권이전의 등기와 선후는 이 대항관계를 규율함에 있어서 어떠한 영향이 없다.⁴¹⁴⁾ 피담보채권의 압류·양도에 수반하는 저당권에 대한 처분제한 및 이전은, 어느 것도 주된 권리인 채권에 부수하여 생기는 것이고, 그 관계를 저당권의 독립성을 인정하여 물권에 관한 대항관계로서 규율하는 것은 가능하지 않기 때문이다. 이때 이와 같이 저당권부채권에 대한 압류명령의 제3채무자에 대한 송달이 채권양도의 대항요건 구비시보다 선행한데도 채권양도에 의한 담보권이전의 부기등기가 피담보채권에 대한 압류의 부기등기보다 먼저 되어 있는 때에 이를 어떻게 처리해야 하는가라는 문제가 있는데, 이에 관해서는 이하 Ⅲ. 4. 기입등기의 효력 부분에서 다시 보기로 한다.

그리고 뒤에서 다시 보듯이, 저당권부채권을 압류하여 본조에 의한 등기가 되면, 압류채권자는 제3자에 대한 대항요건을 구비하게 되지만, 나아가 추심권을 취득한 후 그 등기사항증명서를 제출하는 것에 의해 간이하게 부동산경매의 신청을 하는 것이 가능하다는 이점(利點)도 있다.

2. 압류의 저당권에 대한 효력

가. 저당권에 대한 처분제한효

저당권부채권의 압류명령이 제3채무자에게 송달되어 압류의 효력이 생기면, 저당권자는 압류채권자와의 관계에 있어서 그 채권뿐만 아니라 저당권에 대하여도 그 처분이 금지된다.

가령 피담보채권의 일부에 대하여만 압류될 뿐이더라도 저당권에는 이른바 불가분성이 있으므로 피담보채권 일부의 압류 효력이 저당권 전부에 미치게 된다.

그리고 피담보채권이 압류되면 그 채권에 대해 종된 권리인 저당권에도 처분제한효가 생긴다고 말할 수 있지만, 이러한 이치는 채권질권부채권 등을 압류한 경우에도 동일하다.

414) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 337.

그러나 질권자(집행채무자)가 가지는 질권의 목적재산으로 되어 있는 채권의 채무자(제4채무자)에 대하여 당해 질권에도 압류의 효력이 미치고 있는 것을 통지하지 않는 한, 그 채무자(제4채무자)가 질권자(집행채무자)에게 지급해버릴 위험을 미연에 방지할 수가 없다. 그래서 이 경우에는 그 채권에 미치는 압류의 처분제한효를 공시해 놓기 위해 본조(민집 제228조)를 유추적용하여 질권의 목적으로 되어 있는 채권의 채무자(제4채무자)에 대하여 압류가 된 뜻을 통지해야 한다고 해석된다.⁴¹⁵⁾

나. 압류의 효력발생 후 이해관계인의 지위

1) 압류채권자의 지위

저당권부채권에 대하여 압류의 효력이 생기면 압류채권자는 본조에 의해 법원사무관등에 대해 피담보채권이 압류된 뜻의 등기를 촉탁해달라고 신청할 수 있다.

그리고 압류채권자는 위 압류명령에 기초하여 추심명령을 발령받을 수 있고, 제3채무자가 임의로 지급 또는 공탁을 하지 않은 때에는 자기 명의로 제3채무자를 피고로 하여 추심소송을 제기하는 것이 가능하며, 또 일정한 요건하에 피압류채권에 대하여 전부명령·양도명령 등의 신청을 할 수도 있다.

이와 같은 피압류채권에 대한 현금화수단은 채권집행 일반에 공통된 것이지만, 저당권부채권의 압류의 경우에 특수한 것은 위 추심권 행사의 방법으로서 압류채권자가 저당권을 실행하는 것이 가능하다는 것이다.⁴¹⁶⁾ 즉 압류채권자는 추심권 행사의 방법으로서 피압류채권의 만족을 위해 자기 이름으로 그 압류의 효력이 미치고 있는 저당권의 실행을 신청하는 것이 가능하다. 주된 권리인 피압류채권(피담보채권)의 만족을 위해서 종된 권리인 저당권의 환가권능을 발동시켜 피압류채권의 현금화를 효율화할 수 있다는 것이다.

압류채권자가 저당권의 실행을 신청하면 채권집행절차의 현금화단계에 저당권실행절차가 접목되는 것으로 되고, 저당권실행절차의 배당 단계에서는 기본으로 되는 채권집행절차와의 조정을 도모해야 하는 약간은 복잡한 문제가 생기게 된다. 다음 제4항에서 현금화방법을 살펴볼 때에 이에 대해서 함께 생각해 보기로 한다.

2) 저당권자(집행채무자)의 지위

저당권부채권이 압류되면, 저당권자(집행채무자)는 그 채권 및 저당권의 처분이

415) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 479.; 中野貞一郎, 民事執行法(下), 青林書院新社(1983), 538.; 兼子一(주134), 202.; 宮脇幸彦(주43), 134.

416) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 338.

금지되지만, 압류의 효력이 생긴 후에도 저당권자로서의 지위를 잃는 것은 아니므로 압류의 효력을 해하지 않는 한도에서 저당권자로서의 권리행사를 할 수 있다. 예컨대, 저당권존재확인 등의 소송 제기, 저당권의 침해에 대한 방해배제소송 등 저당권의 가치보존을 위해 필요한 행위를 하는 것이 가능하다.⁴¹⁷⁾ 저당권자는 압류채권자의 압류의 목적을 해하는 행위를 할 수 없는 것이지만, 구체적으로 저당권자의 어떠한 행위가 금지되는가는 당해 행위가 압류의 목적(경제적인 목적, 압류 본래의 목적)에 반하는 것인가, 또 압류채권자의 권리행사에 저촉될 수 있는 것인가 라는 등의 관점에서 보아야 할 것이다.

3) 제3채무자등의 지위

제3채무자의 지위는 압류의 효력이 생긴 후에 집행채무자(저당권자)에게 변제해도 그것을 가지고 압류채권자에게 대항할 수 없는 등 일반 채권집행에 있어서 제3채무자의 경우와 동일하다. 또한 저당권에도 압류의 효력이 미치므로 저당권의 대상으로 되어 있는 권리의 귀속주체가 제3채무자 이외의 자인 경우, 그 자의 지위는 제3채무자에 준하여 취급된다.

다. 원본 확정 전의 근저당권부채권에 대한 압류의 효력

1) 압류의 근저당권에 대한 효력

근저당권은 설정계약으로 정해진 일정한 범위에 속하는 불특정의 채권을 최고액 범위 내에서 담보하는 저당권의 일종이지만(민법 제357조), 원본확정 전에 근저당권자가 설정계약으로 정해진 일정한 범위에 속하는 채권을 취득한 후 그 채권이 양도 또는 대위변제되면 그 채권은 근저당권의 피담보채권의 범위로부터 이탈하게 되므로(민법 제357조 참조),⁴¹⁸⁾ 위 근저당권에 대하여는 수반성이 부정된다.⁴¹⁹⁾

따라서 이와 같이 근저당권이 담보하는 채권의 범위에 속하는 채권이 원본확정

417) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 338.

418) 박윤직, 물권법(민법강의Ⅱ), 박영사(1994), 659.; 근저당권이 확정되지 아니하여 채권자와 채무자 사이에 계속적으로 거래관계가 이루어지고 있는 사이에 이미 발생한 각각의 채권이 양도 또는 대위변제된 경우 이에 수반하여 근저당권이 이전하는가에 대하여는 현재 이전부정설과 이전긍정설로 견해가 나뉘어지고 있으나, 전자의 견해가 타당하다고 본다. 이에 관하여는 제5장 「전부명령」 제4절에서 이전중기의 촉탁을 논할 때에 자세히 보기로 한다.

419) 대법원 2000. 12. 26. 선고 2000다54451 판결; 대법원 1996. 6. 14. 선고 95다53812 판결 등 【판결요지】근저당권은 계속적인 거래관계로부터 발생·소멸하는 불특정다수의 채권 중 그 결산기에 잔존하는 채권을 일정한 한도액의 범위 내에서 담보하는 것으로서 그 거래가 종료하기까지 그 피담보채권은 계속적으로 증감·변동하는 것이므로 근저당 거래관계가 계속되는 관계로 근저당권의 피담보채권이 확정되지 아니하는 동안에는 그 채권의 일부가 대위변제되었다 하더라도 그 근저당권이 대위변제자에게 이전될 수 없다.

전에 압류된 경우에, 과연 그 압류의 효력이 근저당권에 미치게 되는가가 문제로 되는데, 이에 관하여는 다음과 같이 견해가 나뉘어지고 있다.

가) 소극설⁴²⁰⁾ : 이 설은, ① 근저당권은 설정당사자가 정한 일정한 범위에 속하는 불특정한 채권을 교체할 자유를 가지고 최고액 범위 내에서 담보하는 가치권이요, 설정시에 정한 담보할 채권의 범위도 당사자가 자유로 변경하는 것이 가능한 것이며, 담보할 채권의 범위에 속하는 채권이어도 그것이 제3자에게 이전된 경우에는 담보할 채권의 범위로부터 이탈하는 것이므로 이와 같이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권과의 결부(結付)가 약한 담보권에 대하여, 그러한 채권이 압류된 경우에 당해 근저당권에 대하여도 압류의 효력을 미친다고 보기에는 의문이 있는 점, ② 원본확정전의 근저당권에 대하여는 엄격한 의미에서의 피담보채권이라는 것을 관념하기가 어렵고, 근저당권의 피담보채권은 원본이 확정된 때에 존재하는 채권이며, 원본확정전에 담보할 채권의 범위에 속하는 개개의 채권은 근저당권의 피담보채권 그 자체가 아니라 장래 피담보채권으로 될 수 있는 자격을 가지는 말하자면 단순한 그 후보자(候補者)에 불과한 점, ③ 따라서 원본확정 전에 그와 같은 개개의 채권이 압류되어도 근저당권의 피담보채권 자체가 압류된다고는 말할 수 없기 때문에, 그 압류의 효력은 근저당권에는 미치지 않는다고 해석해야 하는 점, ④ 또한 위 압류의 효력이 근저당권에 미치게 되면 압류채권자가 근저당권을 실행하여 근저당 거래를 종료시켜버릴 수 있게 되고, 나아가 근저당권자의 권리행사에 대해 압류채권자들의 동의를 요하는 것으로 되어 근저당권의 성질에 반하게 되는 점 등을 그 근거로 하여 위의 경우 압류의 효력이 근저당권에 미치지 않는다고 보는 견해이다.

나) 적극설⁴²¹⁾ : 이 견해는, ① 원본확정 전에 있어서는 근저당권이 담보할 채권의 범위도 당사자가 자유롭게 변경하는 것이 가능하고, 또 담보할 채권의 범위에 속하는 채권이어도 그것이 제3자에게 이전된 경우에는 담보할 채권의 범위로부터 이탈하지만, 그와 같은 사태가 생기지 않고 그대로 근저당권이 확정되면 담보할 채권의 범위에 속하는 개개의 채권도 근저당권의 피담보채권으로 되는 것이므로 원본확정 전에 있는 그와 같은 채권도 일응 그 때의 피담보채권으로서 존재하고 있다고 말할 수 있는 점, ② 또한 원본확정 전에 담보할 채권의 범위에 속하는 개개의 채권은 잠재적

420) 柚木馨, 高木多喜男 共著, 擔保物權法, 有斐閣(1986), 447.; 川井建, 擔保物權法, 青林書院(1981), 162.

421) 宮脇幸彦(주43), 133.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 476.; 田中康久(주127), 312.; 中野貞一郎, 위 民事執行法(上), 537.

이긴 해도 채무자의 일반재산만을 목적으로 하는 일반채권보다도 높은 담보가치를 가지는 것이므로 근저당권 자체를 압류하여 현금화하는 방법이 없는 이상 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권의 압류의 효력은 근저당권에 미치는 것으로 해석해야 하는 점, ③ 그리고 문리해석으로도 원본확정 전 근저당권의 수반성이 부정되는 것은 채권양도 등의 경우에 한정되는 것인데, 원본확정 전의 채권에 대하여 압류가 된다고 하더라도 그것에 의해 바로 채권의 주체에 변경이 생기는 것은 아니므로 이를 위 채권양도 등과 동일하게 보기 어려워 그 수반성도 긍정될 수 있는 점, ④ 근저당권도 저당권의 일종이므로 그 성질에 따른 특칙 규정이 있는 외에는 보통저당권과 동일한 규율을 받아야 하며, 원본확정 전의 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권에 대한 압류의 효력이 근저당권에 미치지 않는 것이라는 특별한 규정도 존재하지 않기 때문에, 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권이 원본확정 전에 압류된 경우 그 압류의 효력은 근저당권에 미치는 것이라고 해석해야 하는 점 등을 그 이유로 열거하면서 위의 경우에 압류의 효력이 근저당권에 대해 미친다고 보는 입장이다.

위와 같이 견해가 대립되고 있으나, 생각건대 ① 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권은 예를 들어 원본 확정 전이라고 해도 그대로 근저당권이 확정되면 근저당권에 의해 우선변제를 받을 수 있는 관계에 있어서, 무담보채권(일반채권)보다도 높은 가치를 가지고 있다고 말할 수 있는 점, ② 위 소극설에 서게 되면 근저당권이 가지는 담보가치에 대한 강제집행 방법이 폐쇄되고 마는 점, ③ 또 위에서 본 것처럼 저당권부채권이 압류된 경우에 그 채권에 대한 압류의 효력이 그 종된 권리인 저당권에도 미치는 근거는 이른바 저당권의 수반성에서 이를 찾는 것이 일반적인데, 민법 제357조에 의해 원본 확정 전에 근저당권의 수반성이 부정되는 것은 채권양도 등의 경우에 한정되는 것이고, 원본확정 전의 채권에 대하여 압류가 되어도 그것에 의해 바로 채권 주체에 변경이 생기는 것은 아니므로 이 경우는 수반성의 문제도 해결될 수 있는 점, ④ 그리고 소극설이 그 이유로 하는 압류의 효력이 근저당권에 미친다고 해석하면 압류채권자가 근저당권을 실행하여 근저당거래를 종료시키게 되어 타당하지 않다는가, 근저당권자의 권리행사에 대해 압류채권자들의 동의를 요하는 것으로 되어 근저당권의 성질에 반한다는 것 등도 위와 같은 근저당권이 파악하는 담보가치에 대하여 강제집행을 허용해야 한다는 집행법상의 요청 앞에서는 어쩔 수 없는 것으로서 시인되어야 하는 점 등 여러 가지 이유를 고려할 때, 위 적극설이 보다 합

리적인 견해라고 보여지므로 이에 찬동하기로 한다.

또한 근저당권은 그 원본 확정 후에는 저당권의 수반성에 관한 한 보통저당권과 동일한 것으로 되고, 원본 확정 후에 근저당권의 피담보채권이 압류된 경우에는 보통저당권의 피담보채권이 압류된 경우와 동일하게 그 압류의 효력은 당연히 근저당권에 미치게 된다.

2) 근저당권부채권 압류 후의 문제점

가) 피압류채권의 양도

원본확정 전의 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권이 압류되어 압류의 효력이 생긴 후에 근저당권자가 피압류채권을 다른 사람에게 양도해도 그 압류에 의해 피압류채권의 처분은 금지되어 있는 것이므로 그 양도는 압류채권자에게 대항할 수 없다(상대적 무효). 즉 근저당권자는 피압류채권이 근저당권의 파담보채권의 범위로부터 이탈한 것을 압류채권자와의 관계에서는 대항할 수 없다.

따라서 압류채권자는 양도에 관계된 채권(피압류채권)이 그 양도 후에도 근저당권자에게 귀속하고, 근저당권에 의해 담보되는 것이라고 주장할 수가 있다(등기의 유무에 관계없이).⁴²²⁾

또한 압류채권자가 원본확정 전의 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권을 압류한 후에 그 피압류채권에 대하여 전부명령을 얻은 경우, 그 채권은 압류채권자에게 귀속하는 것으로 됨과 동시에 근저당권의 피담보채권의 범위로부터 이탈하게 되므로 근저당권은 그 수반성이 부정되게 되어 근저당권에 미치고 있던 압류의 효력도 소멸하게 된다(이에 대하여 자세한 것은 제5장에서 전부명령에 관해 논의할 때에 살펴보기로 한다).

나) 근저당권의 처분 등

압류의 효력이 근저당권에 미치는 결과, 당해 근저당권이 파악하고 있는 담보가치를 감소시키는 행위는 압류의 처분금지효에 의해 할 수 없게 된다. 따라서 원본 확정 전의 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권이 압류된 후에는 그 압류의 효력이 근저당권에도 미치므로 근저당권자는 근저당권설정자와의 합의에 의해 피담보채권의 범위의 변경, 근저당채무자의 변경을 해도 압류채권자와의 관계에 있어서는 그 효력을 가지지 못하며, 피압류채권은 당해 근저당권이 담보할 채권으로서의 자격

422) 이러한 점은 압류의 대상으로 되는 주된 권리인 채권 자체에 대한 압류의 효력(처분금지효) 문제이므로 그것이 근저당권부채권의 압류인 것을 특별히 고려할 필요는 없는 것이다.

을 상실하지 않는다.⁴²³⁾

또한 근저당권 최고액을 감액하는 변경이나 또는 당사자 합의에 의한 근저당권의 순위 변경 등은 압류채권자에게 불이익하므로⁴²⁴⁾ 그의 승낙이 없는 한 이를 할 수 없다고 본다.

다) 압류채권자, 근저당권자(집행채무자)의 지위

원본확정 전의 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권을 압류한 압류채권자가 스스로 근저당권의 실행을 신청하는 것이 가능한가에 대하여, 압류채권자는 피담보채권의 주체로 되는 것은 아니므로 이를 피담보채권의 양수인과 동일시하는 것은 가능하지 않다고 보아 이를 인정하지 않는 견해도 있다.⁴²⁵⁾

그러나 압류의 효력이 근저당권에도 미친다고 해석되는 이상, 추심권이 생긴 후에는 그 추심권에 기초한 경매의 신청을 긍정할 수밖에 없을 것이다.⁴²⁶⁾

이 경매신청에 의해 근저당권이 담보할 원본이 확정되지만, 피압류채권에 대하여 집행채무자인 근저당권자가 채무불이행인 이상 근저당권이 그와 같은 구속을 받는 것은 불가피하다고 해야 할 것이다. 또 경매절차에 있어서 압류채권자에 대한 배당문제는 제4항에서 후술하기로 한다.

원본확정 전의 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권이 압류되면, 근저당권에도 압류의 효력이 미치고, 근저당권자(집행채무자)는 그 채권 및 근저당권의 처분이 금지되지만, 압류의 효력이 생긴 후에도 근저당권자로서의 지위를 상실하는 것은 아니므로 압류의 효력을 해하지 않는 한도에서 근저당권자로서의 권리행사를 하는 것이 가능하다. 예를 들면, 근저당권존재확인 등의 소송, 근저당권의 침해에 대한 방해배제소송 등 근저당권의 가치보존을 위해 필요한 행위를 할 수 있다.

Ⅲ. 등기된 저당권부채권의 압류와 등기 촉탁

1. 기입등기촉탁의 신청

채권압류사실의 기입등기 신청은 저당권에 의하여 담보되는 채권을 압류한 채권자가 채무자의 승낙 없이 법원사무관등에 대하여 한다(민집 제228조 제1항 전문

423) 竹下守夫, “根抵當權の被擔保債權の差押・質入とその效力”, 不動産登記法講座Ⅲ, 幾代通, 297.

424) 我妻榮, 新訂擔保物權法, 岩波書店(1972), 498.

425) 我妻榮(주424), 502.

426) 吉野 衛外, 위 注釋民事執行法(6), 279.

).⁴²⁷⁾

민사집행법 제정 전의 구 민사소송법 제562조는 이 경우 집행법원이 촉탁하는 것으로 규정하고 있었으나, 민사집행법에서는 법원사무관등이 등기촉탁을 하는 것으로 바꾸어 규정하였다. 등기기입의 신청 여부는 앞서 본대로 신청채권자의 의사에 달려 있다.

신청은 압류명령의 신청과 함께 할 수도 있으나(민집 제228조 제1항 후문), 압류명령신청이 있는 뒤에 별도로 하더라도 무방하다. 그러나 전부명령이 확정된 후와 같이 집행절차가 종료한 뒤에는 신청할 수 없고, 이 경우에는 직접 저당권이전등기의 촉탁만을 하여야 할 것이다.

압류기입등기를 하기 위해서는 원칙적으로 채무자가 저당권자(또는 저당권에 대한 가등기권자)로 등기되어 있어야 하나, 저당권의 등기가 아직 되어 있지 않거나 또는 말소된 때에는 채권자는 채무자를 대위하여 저당권설정등기 내지 말소회복등기를 신청하고 그에 따른 등기가 되면 압류기입등기를 신청할 수 있으며, 목적부동산의 소유자가 제3채무자가 아니어도 무방하다.

2. 등기의 촉탁

신청을 받은 법원사무관등은 압류채권자로부터 제출된 등기사항증명서 등에 의하여 압류된 채권이 촉탁신청에 관계된 저당권의 피담보채권인가 아닌가에 관한 동일성 여부를 심사한다. 압류된 채권의 존부에 관해서 실체적 심사를 하지 않는 것과 마찬가지로 저당권의 존부에 관한 실체적 심사도 하지 않는다.

법원사무관등은 신청을 심사하여 적법하다면 의무를 지는 저당부동산의 소유자(제3채무자, 물상보증인, 제3취득자)에게 압류명령이 송달된 뒤에 관할 등기소의 등기관에게 압류의 기입등기를 촉탁하여야 한다(민집 제228조 제2항).

압류기입등기의 신청이 적법함에도 법원사무관등이 촉탁을 하지 않거나 적법한 신청을 각하한 때에는 채권자는 민사소송법 제223조의 법원사무관등의 처분에 대한 이의를 집행법원에 신청할 수 있고(민집 제23조), 이 이의를 각하한 재판에 대하여는 통상항고를 할 수 있다(민소 제439조).

또한 압류된 채권과 등기기록에 표시된 피담보채권 사이에 그 표시에서 분명하게 동일성이 없다고 인정되는데도 촉탁에 의한 등기가 된 경우에는 집행채무자나 소

427) 별지서식 [3-12] 채권압류 기입등기촉탁서 참조(제3장 말미 수록)

유자가 그 처분에 대하여 이의를 신청할 수 있다고 해석된다. 이미 저당권의 목적물에 다른 채권자의 압류기입등기나 처분금지가처분등기가 되어 있더라도 촉탁에 지장이 없다.

등기촉탁서에는 등기관리자로 「압류채권자」를, 등기의무자로 「저당권자(채무자)」를 적고, 등기원인은 「법원의 압류명령」이 된다. 그 등기원인날짜는 압류명령이 제3채무자에게 송달되어 압류의 효력이 발생한 날이다. 등기촉탁서에는 등기원인을 증명하는 정보로서 압류명령결정정본을 함께 제출하여야 한다(부동산등기법 제24조, 부동산등기규칙 제46조 제1항 제1호).

3. 기입등기방법

위 압류의 기입등기는 부기등기에 의한다(부동산등기법 제52조 제3호). 한편 저당권이 등록에 의하여 성립하는 경우에는 압류기입등기의 촉탁의 상대방이 각 등록의 소관부서가 된다. 즉 광업권저당의 경우에는 산업통상자원부 광업등록사무소장(광업등록령 제1조의2), 자동차저당 및 건설기계저당의 경우에는 서울특별시·광역시 또는 도지사 및 특별자치도지사(자동차관리법 제7조, 제77조, 동시행령 제17조, 건설기계관리법 제3조), 항공기저당과 댐사용권의 경우에는 국토교통부장관(항공법 제3조, 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제24조) 등이다.

4. 기입등기의 효력

가. 본조에 의한 등기는 부동산등기법 제3조의 「처분의 제한」에 관한 등기이다.

위에서 저당권부채권에 대하여 채권압류와 채권양도가 경합된 경우에, 압류에 수반하는 저당권에 대한 처분제한과 채권양도에 수반하는 담보권 이전의 우열관계는 등기된 저당권에 대한 피담보채권이 압류되었다는 취지의 부기등기가 되어도, 기본이 되는 채권에 관한 대항관계로서, 저당권부채권에 대한 압류명령의 제3채무자에 대한 송달과 채권양도의 대항요건의 구비의 시간적인 선후에 의해서 결정되고, 피담보채권에 대하여 압류의 부기등기와 채권양도에 의한 담보권이전의 부기등기와의 선후에 의하여 결정되는 것은 아니라고 말한 바 있다.⁴²⁸⁾

그런데 저당권부채권에 대하여 그 양도와 압류가 경합하는 경우에 압류명령의

428) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 337. 참조

제3채무자에 대한 송달이 채권양도의 대항요건 구비시보다 선행한데도 채권양도에 의한 담보권이전의 부기등기가 피담보채권에 대한 압류의 부기등기보다 먼저 되어 있는 때에 이를 어떻게 처리해야 하는가라는 문제가 있다(이 경우 등기기록상은 압류등기의 촉탁시에 이미 채권양도에 수반하는 저당권이전의 부기등기가 기입되어 있으므로 그 부기등기 전의 저당권자인 집행채무자를 등기의무자로 하는 압류등기 촉탁은 각하되게 된다).

이에 관하여 실체적으로는 압류가 채권양도에 우선하고 있기 때문에 압류채권자가 채권양도에 수반한 저당권이전의 부기등기에 대한 말소등기청구소송을 제기, 승소하여 위 등기를 말소한 다음 종전의 저당권자를 등기의무자로 하는 압류의 부기등기를 하는 것도 생각해볼 수 있으나, 위 채권양도의 효력은 압류채권자의 압류에 기초한 집행절차와의 관계에 있어서만 대항할 수 없을 뿐이고 만일 위 압류가 실효된 경우에는 유효로 될 수도 있는 것이므로 바로 위 이전의 부기등기를 말소하는 식의 처리는 적절하지 않다.

따라서 이와 같은 경우에는 압류명령을 일종의 집행권원에 준하는 것으로, 또 저당권이전의 부기등기를 갖춘 채권양수인을 압류명령 후의 특정승계인으로 해석하여, 집행법원으로부터 승계집행문을 부여받아 채권양수인이 권리자로 되어 있는 저당권의 등기에 대해 압류의 부기등기를 하는 방법이 타당하다고 본다.⁴²⁹⁾

나. 부동산에 관한 저당권부채권을 압류한 후 본조에 의해 저당권에 대해 압류의 부기등기를 갖추어 두면, 추심권을 취득한 후 그 등기사항증명서를 제출하여 간이하계 부동산경매를 신청할 수 있고,⁴³⁰⁾ 또한 전부명령을 받은 때에는 저당권이 압류채권자에게 이전되므로 전부채권자가 저당권자로서 저당권을 실행할 수 있다[이러한 전부채권자의 저당권 취득은 법률의 규정에 의한 부동산 물권변동(민법 제187조)에 해당하므로 저당권이전의 부기등기는 저당권 실행을 위한 실체법상의 요건은 아니나, 실제로 부동산경매를 진행함에는 저당권이전의 부기등기가 선행되어야 한다].

그리고 제3자가 당해 부동산에 대하여 경매의 신청을 한 경우, 저당권자(집행채무자)에게 배당이 실시되는 것을 저지할 수 있다.

429) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 471.

430) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 338.

IV. 저당권부채권의 현금화방법(저당권실행)

저당권부채권을 압류한 채권자의 현금화방법은, 기본적으로는 일반의 채권집행과 동일하다.

피압류채권(저당권부채권)의 추심을 원칙으로 하고, 피압류채권이 피전부적격을 갖추고 있으면 전부명령이 인정되며, 피압류채권이 조건부인 것 등의 이유로 추심이 곤란하면 양도명령, 매각명령 등 특별한 현금화방법이 인정될 수 있다.

저당권부채권의 압류에 기초한 현금화 방법으로서 특수한 것은 위 추심권 행사의 방법으로서 압류채권자가 그 담보권의 실행을 하는 것이 가능하다는 것이다.

즉 저당권부채권이 압류되면, 그 저당권에 대하여도 당연히 압류의 효력이 미치게 되므로 압류채권자는 추심명령을 발령받아 추심권을 취득하면(추심권이 있어야만 실행이 가능하다) 그 추심의 한 방법으로서 피압류채권(피담보채권)의 만족을 위해 그 종된 권리인 저당권의 환가권능을 발동시켜 자기 명의로 그 압류의 효력이 미치고 있는 저당권의 실행을 신청하는 것이 가능하다. 이와 같이 압류채권자가 저당권의 실행을 신청하면, 채권집행절차의 현금화단계에 저당권의 실행절차가 접합(接合)되게 된다.

추심권을 취득한 압류채권자가 신청한 저당권실행절차는 저당권, 질권 등의 담보권에 기초한 것으로 담보목적재산의 종류에 따라, 부동산경매, 선박경매, 동산경매, 채권 그 밖의 재산에 대한 담보권의 실행으로서 실시된다.

이때 저당권부채권의 압류채권자가 신청채권자로 된다고 하여, 경매절차의 진행에 어떤 차이가 있는 것은 아니고, 특별한 조치가 강구될 필요도 있는 것은 아니지만, 다음과 같은 점은 유의해야 한다.

1. 절차개시문서 등의 제출

먼저 본조의 촉탁에 의해 저당권에 대하여 압류의 부기등기를 경료하면, 그 등기기록은 민사집행법 제264조 제1항의 「담보권이 있다는 것을 증명하는 서류」에 해당되고, 또 저당권의 피담보채권에 대한 추심명령 정본은 민사집행법 제264조 제2항의 「담보권의 승계를 증명하는 서류」로 볼 수 있다. 따라서 추심권을 취득한 압류채권자는 위와 같은 등기사항증명서와 추심명령정본을 제출하여 부동산경매를 신청할 수 있다 할 것이다.

위 저당권에 대하여 압류의 부기등기가 경료되지 않은 경우에 경매의 신청이 가능한지 여부가 문제로 될 수 있지만, 이 경우도 저당권에 대하여 압류의 효력이 미치고 있는 것을 위 저당권등기가 되어 있는 등기사항증명서 및 그 저당권부채권에 대한 압류명령(및 추심명령)正本 등을 제출하는 것에 의해 증명할 수 있으면 그 신청이 가능하다고 볼 것이다.⁴³¹⁾

2. 부동산경매절차에 있어서 압류채권자의 처리

가. 저당권부채권이 압류되면, 저당권자(집행채무자)는 피담보채권의 추심이 금지되고, 피담보채권의 만족을 받을 수 없다는 구속을 받게 된다.

따라서 저당부동산에 대하여 개시된 부동산경매절차에 있어서, 저당권자는 그 저당권에 대하여 배당을 받아 피담보채권을 소멸시키지는 못하고, 압류채권자는 추심권을 취득하면 스스로 경매를 신청하여 저당부동산을 현금화하는 것이 가능하며, 또 본조에 의하여 저당권에 대해 부기등기가 되어 있으면, 다른 자(저당부동산 소유자의 채권자)가 신청한 강제경매 내지는 부동산임의경매의 절차가 진행되어도 그 부동산집행법원은 저당권자(집행채무자)가 가지는 저당권에 압류의 효력이 미치고 있음을 알고 있으므로 채무자인 저당권자에게 배당이 실시되는 것을 저지할 수 있게 된다.

나. 부동산집행법원이 저당권자에 대한 배당금을 지급하려고 할 때에 그에 대하여 위 경매를 신청한 압류채권자 외에 다른 경합하는 압류채권자가 등기되어 있다면, 위 집행법원은 그 배당금을 어떻게 처리해야 할까.

이 경우는 저당권부채권에 대해 압류가 경합하고 있고, 그러한 상황에서는 위 신청 압류채권자에 대해서만 독점적 이익을 부여할 수 없음이 명백하므로 부동산집행법원은 민사집행법 제248조에 따라 공탁을 한 다음 채권집행법원에 대한 사유신고를 하여 채권집행법원으로 하여금 채권배당을 실시하도록 하여야 할 것이다.⁴³²⁾

그 반면에, 등기기록 등 외관상 달리 경합하는 채권자가 없으면 부동산집행법원은 민법 제487조(채권자가 변제를 수령할 수 없는 때)의 변제공탁 또는 민사집행법 제248조의 집행공탁의 방법으로 위 배당금을 공탁하여야 하고(민사집행법 제160조에

431) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 293.

432) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅱ), 683.

의한 배당유보공탁이 아니다), 특히 집행공탁을 할 때에는 채권집행법원에 공탁사유 신고(민집 제248조 제4항, 민집규 제172조)도 하여야 한다.

다. 다른 자가 신청한 강제경매 내지 부동산임의경매절차가 진행되고 있는 경우에 압류채권자가 본조의 부기등기를 경료하지 않은 때에는 채권압류명령 및 추심명령의 정본 등을 제출하여 저당권부채권이 압류되어 있음을 부동산집행법원에 인식시켜 줄 필요가 있다.

압류채권자가 압류의 부기등기도 경료하지 않고 또 저당권부채권의 압류명령 등도 제출하지 않았던 경우에는 경매절차상 그 압류채권자의 존재는 무시될 것이다. 그런 의미에서 부기등기 등의 조치를 취하지 않았던 것으로 인한 불이익은 압류채권자가 부담하게 되는 것이다.

또한 저당권자(집행채무자)가 신청한 부동산경매절차가 진행 중에 당해 저당권부채권이 압류된 경우, 압류채권자는 추심명령을 얻어 저당권자의 지위를 승계한 후 그 경매절차를 수계하는 것이 가능하다고 해석된다.

3. 집행채무자에 의한 경매신청의 가부

가. 저당권부채권이 압류된 경우 집행채무자인 저당권자가 경매신청을 하는 것이 가능한가라는 문제가 있는바, 이는 앞의 V. 3. 다.에서 살펴본 압류된 채권의 채무자가 제3채무자에 대해 강제집행을 할 수 있는가라는 논의와 유사한 것이다.

이에 대하여는 저당권부채권에 대하여 압류의 효력이 생긴 후에는 저당권은 피담보채권의 추심이 금지되므로(압류의 존재는 저당권 실행의 집행장해사유), 그 저당권의 실행을 신청할 수 없다고 해석하는 견해⁴³³⁾도 있을 수 있지만, 압류의 효력이 생긴 후에도 집행채무자는 저당권자로서의 지위를 상실하는 것은 아니므로⁴³⁴⁾ 집행채무자가 경매신청을 하는 것도 가능하고, 다만 압류채권자를 위해서는 부동산경매절차에 있어서 저당권자가 배당에 의해 현실적인 만족을 얻는 것을 저지하면 족하다고 생각한다.⁴³⁵⁾

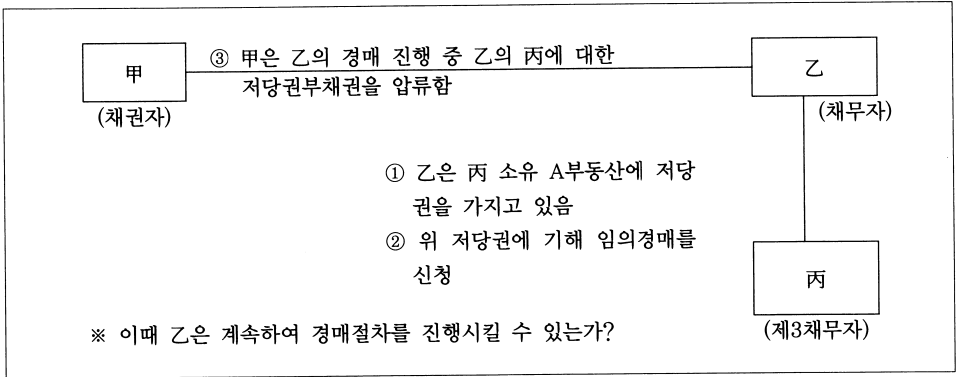
나. 나아가 저당권자에 의한 경매절차가 진행 중에 있는 경우에 저당권부채권이 압류되었다면 집행채무자인 저당권자가 그 절차를 진행시키는 것이 가능한가 어떤가

433) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 474.

434) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 338.

435) 吉川大二郎, 判例保全處分, 法律文化社(1961), 239. 이하

라는 문제도 있다.



현재 이에 관하여 다수설⁴³⁶⁾은 이 경우 피담보채권에 대한 압류의 존재를 저당권실행의 집행장애사유로 보아 압류가 선행하고 있는 경우라면 저당권자는 저당권 실행을 할 수 없고, 이미 저당권자가 그 실행의 신청을 하여 절차가 진행되던 중에 압류가 된 경우라면 그 단계에서 저당권부채권의 압류의 효력이 소멸하든가 혹은 압류채권자가 저당권실행의 신청채권자의 지위를 승계한 후 그 절차를 승계할 때까지 당해 절차가 정지되는 것으로 보고 있으며, 우리의 현재 실무⁴³⁷⁾ 또한 위 다수설의 견해를 취하고 있는 듯 하다.

그러나 ① 위에서와 같이 압류의 효력이 생긴 후에 집행채무자는 저당권자로서의 지위를 상실하는 것은 아닌 점, ② 이 경우 압류채권자가 절차를 승계할 때까지 절차를 정지한다고 한다면 채권자의 승계 의사 여하에 따라 절차가 지연되거나 불안정해질 수 있는 점, ③ 집행채무자가 행한 절차가 계속 진행되더라도 그 최종적인 만족만을 저지할 수 있다면 압류채권자에게 전혀 불이익하지 않는 점, ④ 압류채권자 입장에서 절차의 수계를 원하지 않을 수도 있는데, 그 수계가 있어야만 집행절차를 진행시킬 수 있다고 한다면 이는 오히려 그에게 부담이 될 수 있는 것이며, 또 만일 압류채권자가 수계할 수 없는 상황이라면 신속을 요하는 집행절차가 하릴없이 공전(空轉)될 수 있는 점, ⑤ 위 절차를 계속 진행시키고 다만 배당 또는 변제만을 압류채권자에게 확실하게 지급할 수 있다면 보다 빨리 변제를 받게 되어 위 압류채권자에게 이익이 될 수 있는 점 등 여러 사정을 감안하여 볼 때 이 경우 절차를 계속 진행시키고, 다만 집행채무자가 배당에 의해 현실의 만족을 얻는 것을 저지해두면 족하다

436) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 474.; 田中康久(주127), 313.

437) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 338.

는 견해⁴³⁸⁾가 타당하다고 본다.

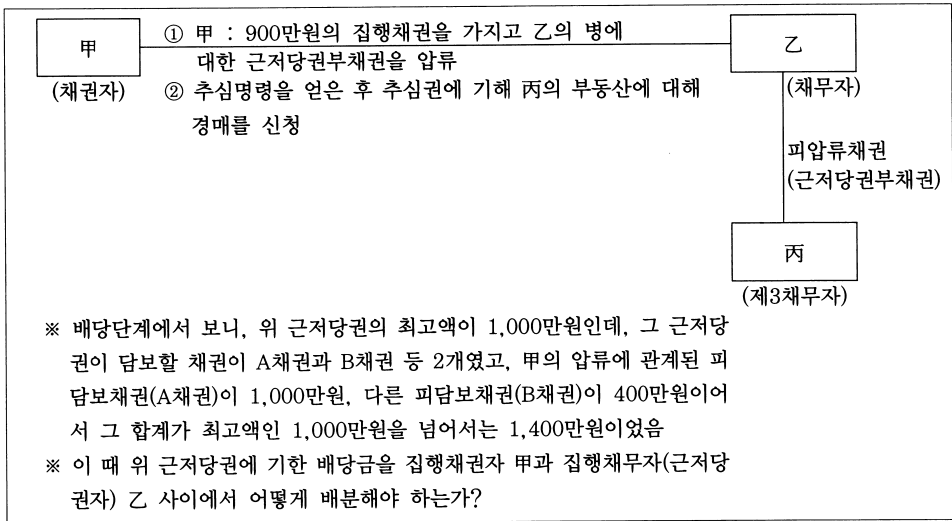
다. 위와 같이 집행채무자가 경매를 신청할 수 있다거나 혹은 이미 진행한 경매 절차를 속행할 수 있다는 입장에 설 경우, 어느 단계까지 집행절차를 진행할 수 있는지, 그리고 어떻게 집행채무자의 최종적 만족을 저지할 수 있는지 등이 문제될 수 있으나, 이에 관하여는 앞서 본 것처럼(Ⅳ. 3.), 이 경우 집행법원은 배당절차까지 진행할 수 있고, 다만 집행채무자가 만족을 얻으면 아니되므로 배당금을 민법 제487조에 따라 변제공탁을 하거나 또는 민사집행법 제248조에 의해 집행공탁을 하는 방법으로 공탁하면 될 것이다.

4. 근저당권부채권에 대한 압류의 경우

가. 앞서 본대로 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권이 원본확정 전에 압류된 경우도, 그 압류의 효력은 근저당권에 미친다고 해석되고, 근저당권의 목적부동산이 경매된 경우 압류채권자의 경매절차상의 지위는 저당권부채권에 대한 압류의 경우와 기본적으로 동일하지만, 근저당권의 성질상, 그 배당단계에서 압류채권자의 근저당권자에 대한 우선변제권의 행사를 어떠한 범위 또는 방법으로 인정할 것인가라는 문제가 생긴다.

나. 원본확정시에 압류에 관계된 근저당권부채권을 포함한 근저당권이 담보할 채권의 합계가 최고액 범위 내에 있는 경우에는 압류채권자는 피압류채권에 대하여 전액 변제를 받을 수 있기 때문에 별 문제가 없지만, 위 근저당권이 담보할 채권의 합계가 최고액의 범위를 초과하고 있는 경우에는 문제가 발생하게 된다.

438) 吉川大二郎, 判例保全處分, 法律文化社(1961), 239, 이하



이 문제에 관하여는, ① 수개의 피담보채권 중 1개가 압류된 경우라도 이를 고려함이 없이 민법상의 법정충당에 의해 우선순위가 정해지게 되므로 배당금 가운데 법정충당규정에 의해 압류채권의 변제에 충당되어야 할 부분이 있는 때는 그 금액이 압류채권자에게 배당되지만, 압류채권의 변제에 충당할 부분이 없는 때에는 압류채권자에 대하여는 배당되지 않는 것으로 된다는 견해(법정충당설),⁴³⁹⁾ ② 압류채권자와 근저당권자를 근저당권의 준공유자에 준하는 것으로 보아, 압류채권자와 근저당권의 각 채권액의 비율에 응하여 안분해야 한다는 견해(동순위설),⁴⁴⁰⁾ ③ 안분비례로는 근저당권자의 의사에 의해 피담보채권총액을 최고액 이상으로 증가시키는 것에 의해 압류의 효력이 잠탈되는 결과로 되고, 또 압류채권자는 그 채권액 전액이 만족되지 않으면 근저당권자가 받을 배당금의 지급청구권을 압류할 수 있는 것으로 되므로 압류채권자가 피압류채권 전액에 대해 우선한다는 견해(압류채권자우선설)⁴⁴¹⁾ 등이 있다.

이 경우의 압류채권자와 근저당권자는 근저당권을 준공유하는 입장에 있다고 볼 수 있지만, 압류채권자와 근저당권자가 채권집행상의 집행채권자와 집행채무자의 관계에 있는 것을 고려하여, 근저당권의 목적부동산이 경매된 경우의 배당금의 분배에 대하여는 최고액의 범위 내에서 압류채권자의 우선권을 긍정해야 할 것이다.⁴⁴²⁾

따라서 위 사례에서는 위 근저당권의 피담보채권액이 채권최고액인 1,000만 원

439) 鈴木忠一, “確定前の根抵當權の被擔保債權の差押えと質入れの效力”, 金融法務事情 993호, 7.

440) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 476.[稻葉威雄 집필부분]

441) 竹下守夫(주423), 294.

442) 吉野 衛 外, 위 注解民事執行法(6), 297.

을 넘어서고 있더라도 위 근저당권에 대해 배당되는 배당액은 최고액을 기준으로 한 1,000만 원일 것인데, 압류채권자인 甲의 집행채권이 900만 원이므로 위 배당액 중 900만 원을 甲에게 지급하고 나머지 100만 원을 집행채무자인 乙에게 지급해야 할 것이다(만일 이 경우 甲의 압류채권이 위 배당액인 1,000만 원이거나 이를 넘어서고 있다면 위 배당액 1,000만 원은 甲에게 우선하여 돌아가야 할 것이다).

그리고 이러한 이치는 원본확정 후에 피담보채권의 일부가 전부명령의 확정에 따라 전부채권자에게 이전한 경우에도 동일하다고 보아야 할 것이다.⁴⁴³⁾

다. 또한 전술한 대로 압류채권자가 원본확정 전의 근저당권이 담보할 채권의 범위에 속하는 채권을 압류한 후에 그 피담보채권에 대하여 전부명령을 얻은 경우에는, 그 채권은 근저당권의 피담보채권의 범위로부터 이탈하고, 또 그에 따라 근저당권에 대해 미치고 있던 압류의 효력도 소멸하게 되므로 압류채권자로서는 추심권의 취득 후 근저당권의 실행을 신청하여 원본을 확정시킨 후에 전부명령을 얻는 것이 유리할 것이다.

V. 저당권 이외의 담보권이 있는 채권의 압류

저당권이 아닌 등록된 질권이 있는 채권의 압류에 있어서도 위 설명에 준하여 취급하여야 한다. 예컨대 저작권재산권과 출판권을 목적으로 하는 질권(저작권법 제54조, 제63조), 특허권·실용신안권·디자인권·상표권과 그 전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권(특허법 제85조, 실용신안법 제18조, 디자인보호법 제88조 제1항 제3호, 상표법 제39조) 등이 그것이다.

이와 같은 질권이 있는 채권의 압류기입등록의 촉탁은 저작권재산권 및 출판권의 경우에는 문화체육관광부장관(저작권법시행령 제25조, 제26조), 나머지 권리의 경우에는 특허청장(특허권 등의 등록령 제17조)에게 한다. 이러한 재산권에 대한 질권의 실행은 민사집행법 제273조에 의한다.

동산질권이 있는 채권을 압류한 경우에는 법률에 명문의 규정은 없으나, 채권자가 구체적으로 질물을 밝힌 압류명령에 기초하여 집행관에게 채무자가 소지하는 질물의 인도를 구할 수 있다고 해석된다.⁴⁴⁴⁾ 그리하여 압류채권자가 추심권을 취득하면

443) 東京地裁債權執行等手續研究會(주115), 125.

444) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 339.; 宮脇幸彦(주43), 113.

민사집행법 제271조의 규정에 의하여 경매를 실시할 수 있다.

채권질권이 있는 채권을 압류한 경우에도 직접적인 규정은 없으나 민사집행법 제228조를 준용하여 채권자의 신청에 따라 질권의 목적인 채권의 채무자에게 압류명령을 송달하고 압류채권자가 추심권을 취득하면 민사집행법 제273조의 규정에 의하여 질권을 실행할 수 있다고 해석된다.⁴⁴⁵⁾

그 밖에 유치권이나 선박우선평권 등의 담보권이 있는 채권을 압류한 경우에도 이러한 담보권에 압류의 효력이 미치므로 압류채권자가 추심권을 얻으면 담보권을 행사할 수 있다. 유치권의 경우에는 압류단계에서 집행관에게 목적물의 인도를 구할 수 있을 것이다.

한편 동산담보권부 채권의 압류에 따른 부기등기는, 현행 동산담보제도의 등기편제가 인적편성주의를 채택하고 있어서 동산 자체의 압류사실을 공시할 실익이 크지 않고 이에 관한 등기시스템도 갖추어지지 않았기 때문에 행해지지 않고 있다.

VI. 압류기입등기의 말소

1. 압류된 채권이 소멸한 경우

압류기입등기가 된 후에 압류된 채권이 변제 또는 공탁에 의하여 소멸되었음을 증명하는 문서가 제출된 때에는 법원사무관등은 신청에 따라 그 등기의 말소를 촉탁하여야 한다(민집규 제167조 제4항). 이는 저당권이 있는 채권이 압류된 경우에 저당권 등의 실행으로서 경매에 의한 변제, 지급, 공탁 등에 의하여 소멸한 경우에 그러한 사실을 증명하는 문서가 제출되면 법원사무관등이 신청에 따라 그 압류기입등기의 말소를 촉탁하여야 하는 것을 규정한 것이다.

압류명령이 취하되거나 즉시항고 또는 청구이의의 소 등에서 압류명령의 취소결정이 확정된 때에도 같다(민집규 제167조 제4항). 전자의 경우에는 채무자가, 후자의 경우에는 압류채권자가 각각 그 촉탁비용을 부담한다(민집규 제167조 제5항). 여기서 촉탁의 신청권자는 채무자와 압류채권자로 해석되는데, 담보권설정자나 소유자도 말소촉탁을 신청할 수 있다는 견해도 있다.

저당권이 있는 채권에 관하여 전부명령이나 양도명령(민집 제241조 제1항 제1호)이 확정된 때 또는 매각명령(민집 제241조 제1항 제2호)에 따른 매각이 종료된

445) 宮脇幸彦(주43), 134.

때에는 법원사무관등은 채권을 취득한 채권자 또는 매수인의 신청에 의하여 저당권이 전등기와 아울러 압류기입등기의 말소를 촉탁하여야 하고, 말소촉탁을 함에는 전부명령이나 양도명령의 정본 또는 매각조서의 등본을 붙인 서면으로 하여야 한다(민집규 제167조 제2항). 그리고 그 촉탁에 관한 비용은 채권을 취득한 채권자 또는 매수인이 부담하여야 한다(민집규 제167조 제3항).

저당권이 있는 채권에 관하여 추심명령이 있어 추심채권자가 저당권을 실행하여 매각절차가 종료한 때에는 압류기입등기는 법원사무관등의 촉탁에 의하여 말소된다(민집규 제167조 제4항). 저당권이 실행되지 아니하고도 추심이 완료되어 추심신고가 있으면 법원사무관등은 직권으로 말소촉탁을 하여야 한다.

2. 압류기입등기가 잘못 기재된 경우

저당권에 관하여 압류기입등기가 기재되었으나 실제로는 저당권이 존재하지 않는 등 압류기입등기가 잘못 기재되었음을 주장하는 목적부동산의 소유자는 그가 제3채무자이든 그 밖의 제3자이든 불문하고 제3자이의의 소에 의하여 압류기입등기의 말소를 청구할 수 있다.⁴⁴⁶⁾

압류된 채권이나 저당권이 채무자에게 속하는 것이 아니라고 주장하는 제3자도 마찬가지로 제3자이의의 소를 제기하여야 한다.⁴⁴⁷⁾

집행법원은 실체관계를 판단할 권한이 없으므로 집행에 관한 이의(민집 제16조)로 다룰 것은 아니다. 다만 압류된 채권과 등기기록상 저당권의 피담보채권이 분명하게 일치하지 않는다는 것을 이유로 할 때에는 민사소송법 제223조의 법원사무관등의 처분에 대한 이의를 집행법원에 신청할 수 있다(민집 제23조).⁴⁴⁸⁾

446) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 454.

447) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 477.

448) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 454.

제5절 지시채권의 압류(민집 제233조)

I. 서

어음·수표 그 밖에 배서로 이전할 수 있는 증권으로서 배서가 금지된 증권채권의 압류는 법원의 압류명령으로 집행관이 그 증권을 점유하여야 한다(민집 제233조).

이 규정은 민사집행법 제189조 제2항 제3호가 배서가 금지되지 아니한 유가증권을 유체동산으로 보아 그에 대한 강제집행을 유체동산 강제집행절차에 따르도록 규정하고 있는 것에 대비하여, 채권집행의 대상이 되는 유가증권을 지시증권 중에서 배서가 금지된 것으로 한정된 다음 이러한 유가증권을 압류하기 위해서는 집행관의 점유 외에 법원의 압류명령이 필요하다고 한 것에 그 의의가 있다.⁴⁴⁹⁾

II. 압류명령 및 증권점유

1. 압류명령의 내용

증권채권에 대한 압류명령에는 「채무자의 제3채무자에 대한 별지목록 기재의 약속어음에 기초한 채권(화물상환증에 기초한 별지목록 기재의 유체동산 인도청구권)을 압류한다.」라고 적고, 집행관이 그 증권을 점유하게 되므로 압류명령에 지급금지문구나 처분금지문구를 적을 필요는 없으나 적더라도 관계없다.⁴⁵⁰⁾

또한 압류명령만 가지고도 집행관이 증권을 점유할 수 있으므로 위 압류명령에 증권의 점유명령을 적을 필요가 없지만 적어도 무방하다.⁴⁵¹⁾ 그 기재는 「채권자의 위임을 받은 집행관은 채무자로부터 위 약속어음을 빼앗아 점유하여야 한다.」라고 적으면 될 것이다.

449) 1990. 1. 13. 개정 전에 본조는 “어음, 수표 기타 배서로 이전할 수 있는 증권채권의 압류는 집달리가 그 증권을 점유하여야 한다.”라고 규정하고 있어서 해석상, ① 본조에 의한 집행대상인 증권채권과 유체동산에 대한 강제집행에 관한 구민소법 제544조 내지 제546조 소정의 유가증권이 어떻게 구별되는가 하는 점과 ② 본조의 증권채권압류를 유체동산의 압류로 볼 것인가 아니면 채권압류로 볼 것인가 하는 점이 문제가 되었다. 본조는 같은 날 개정된 구민소법 제527조 제2항 제3호가 배서가 금지되지 아니한 유가증권은 유체동산으로 보도록 규정하고 있는 것에 대응하여 채권집행의 대상이 되는 유가증권은 배서가 금지된 것에 한정하고, 다른 한편 종래 판례(대법원 1976. 3. 23. 선고76다198 판결)와 같이 채권집행설을 따라 이러한 유가증권의 압류를 위해서는 집행관의 점유 외에 법원의 압류명령을 요하는 것으로 함으로써 입법적으로 해결하였다. 2002. 1. 26. 민사집행법을 제정할 때에도 이러한 취지의 규정이 그대로 유지되고 있다.

450) 임순명, “어음·수표에 대한 강제집행”, 재판자료(31), 651.; 남기정, 위 실무강제집행법(3), 133.

451) 남기정, 위 실무강제집행법(3), 134.

그리고 지시채권은 그 성질상 불가분채권이므로 그 채권의 일부만을 압류할 수는 없다.⁴⁵²⁾

이 압류명령의 효력은 압류명령상 제3채무자로 표시되어 있지 아니한 제3자에게는 미치지 않으므로 그에 대하여 압류하기 위해서는 새로운 압류명령이 있어야 한다.⁴⁵³⁾

위 압류명령을 송달함에 있어서는 채권자의 신청에 의하여 집행관이 증권의 점유를 취득함과 동시에 직접 채무자에게 송달하게 하면 압류명령의 송달로 인한 채무자의 집행 방해를 막을 수 있다.⁴⁵⁴⁾

2. 집행관의 증권 점유

가. 채권자는 위 압류명령에 기초하여 집행관에게 증권의 압류집행을 위임하고, 위임을 받은 집행관은 민사집행법 제257조의 동산인도청구권집행에 준하여 집행채무자가 점유하는 증권을 빼앗아 점유한다.

이러한 집행관의 증권 점유는 압류의 효력발생요건이므로 집행관의 이러한 증권 점유가 없으면 압류명령의 송달만으로는 법률상 효력이 없다.⁴⁵⁵⁾ 제3자가 증권을 점유하고 있는 경우에 그 제3자가 제출을 거부하는 때에는 위 방법에 의할 수 없고 채무자의 증권인도청구권에 대하여 강제집행(민집 제259조)을 하여야 한다.⁴⁵⁶⁾

나. 집행관이 점유를 취득할 당시 채무자가 증권을 점유하고 있는 경우에는 집행관 스스로가 계속 점유하여야 하고, 채무자로 하여금 보관하도록 하여서는 안 된다.⁴⁵⁷⁾ 증권의 점유를 취득한 집행관은 집행조서를 작성하여 그 등본을 집행법원에

452) 이재성, “유가증권이 발행된 채권이 집행방법, 평석집(Ⅲ), 111.; 임순명(주450), 751.

453) 남기정, 위 실무강제집행법(3), 134.

454) 임순명(주450), 651.

455) 대법원 1988. 6. 14. 선고 87다카2599·2600 판결【판결요지】[1] 상법 제461조에 의하여 주식회사가 이사회 결의로 준비금을 자본에 전입하여 주식을 발행할 경우에는 회사에 대한 관계에서는 이사회 결의로 정한 일정한 날에 주주명부에 주주로 기재된 자만이 신주의 주주가 된다고 할 것이므로 갑이 병 주식회사의 기명주식을 실질적으로 취득하였으나 병 주식회사의 이사회가 신주를 발행하면서 정한 기준일 현재 갑이 기명주주의 명의개서를 하지 아니하여 을이 그 주주로 기재되어 있었다면 병 주식회사에 대한 관계에서는 신주의 주주는 을이라 할 것이다. [2] 갑이 자기를 위하여 압류된 주식에 대하여 추심에 갈음한 양도명령을 받아 그 양도명령이 제3채무자인 병에게 송달되었다면 설사 을을 위하여 한 위 주식에 대한 압류명령이 갑이 받은 양도명령과 동시에 제3채무자인 병에게 송달되었다고 하더라도 집달관이 위 주식을 점유하지 않는 한 그 압류명령의 송달자체만으로는 법률상 아무런 효력이 없다고 할 것이므로 갑에 대한 위 양도명령은 을의 압류로 인하여 그 효력에 아무런 지장이 없다.

456) 이재성(주452), 107.; 남기정, 위 실무강제집행법(3), 136.

457) 그러한 방법은 지시증권의 성질상 압류의 실효를 거두기 어렵기 때문이다[남기정, 위 실무강제집행법(3), 136.].

제출하여야 한다.

다. 집행관은 점유한 증권을 채권자가 추심명령이나 전부명령을 받아 그 인도를 요구할 때까지 그대로 보관하고, 보관 중 지급기일이 도래하였을 경우에는 지급제시나 저질증서의 작성 등 권리보전을 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.⁴⁵⁸⁾

집행관은 증권을 보관하던 중 지급제시를 하여 증권상의 채무자가 지급하는 어음금 등을 수령할 수 있으며, 이때에는 이를 집행법원에 제출하여야 하고, 그것은 법원보관금이 된다.⁴⁵⁹⁾

III. 압류의 효과

1. 인도증권 압류의 경우

화물상환증이나 창고증권 또는 선하증권 등 특정물의 인도의무를 표창하는 이른바 인도증권만을 압류한 경우에 그 압류의 효력은 인도의 목적물에 미치지 아니하며, 추심채권자의 위임에 따라 집행관이 민사집행법 제243조에 의하여 그 목적물을 인도 받은 때에 비로소 압류의 효력이 그 물건에도 미친다.

반면 위 증권 자체를 압류하지 아니하고 인도의 목적물만을 압류할 수도 있다고 하나, 그러한 경우에는 목적물 등의 보관자가 증권과 상환으로만 인도하겠다는 항변을 할 수 있으므로 대부분 목적물만의 압류는 실효성이 없게 될 것이다.

2. 어음·수표채권 압류의 경우

원인채권과는 별도로 어음·수표채권만이 압류된 경우 제3채무자는 집행채무자의 원인채권 청구에 대하여 어음·수표와 동시이행의 항변을 주장할 수 있고, 또 어음·수표채권을 전부받은 채권자에게 지급하면 이로써 채무자에게 대항할 수 있으나, 집행채무자에 대한 원인채권의 지급으로는 채권자에게 대항할 수 없다.

원인채권만이 압류된 경우에는 그 압류의 효력은 증권채권에까지 미치지 않으므로 제3채무자는 어음·수표의 소지인에 대하여 지급할 의무가 있고, 그 지급이 압류명령 송달 후에 이루어졌더라도 그 지급으로써 압류된 원인채권이 소멸하였다는 것을 압류채권자에게도 대항할 수 있다.⁴⁶⁰⁾ 다만 채무자가 어음·수표채권을 행사할 때에는

458) 남기정, 위 실무강제집행법(3), 128.

459) 이에 대하여는 1990. 1. 13. 개정전 본조의 해석상 채권집행인지 여부와 관련하여 다툼이 있었으나, 채권집행으로 규정된 현행법하에서는 이와 같이 해석하는 것으로 정리가 되었다.

460) 대법원 1984. 7. 24. 선고 83다카2062 판결; 대법원 1994. 3. 25. 선고 94다2374 판결; 대법원 2000. 3. 24. 선고 99다1154 판결 등

원인채권의 압류를 인적항변으로 주장할 수 있다.⁴⁶¹⁾

IV. 지시채권의 현금화절차

1. 서

압류명령에 의하여 집행관이 점유를 취득한 지시채권에 관하여는 다른 채권과 동일하게 추심명령 또는 전부명령, 특별현금화방법(민집 제241조)에 의한 현금화가 가능하다.

이에 관하여는 다음과 같은 점을 유의해야 한다.

채권자는 압류효력 발생 후에 현금화절차를 신청할 수 있으나 이때에는 압류의 효력발생요건인 집행관의 증권점유사실을 증명해야 한다. 이를 위해서 보통 집행관의 압류조서등본을 신청서에 첨부한다.⁴⁶²⁾

집행관이 증권을 점유하지 않은 상태에서 내려진 현금화명령은 효력이 없다.⁴⁶³⁾ 그러므로 압류명령과 현금화명령을 동시에 할 수는 없다. 그러나 현금화명령이 제3채무자에게 송달되기 이전에 집행관의 점유가 있었으면 그 현금화명령은 유효하다고 볼 것이다.⁴⁶⁴⁾

채권자의 신청에 따라 법원이 현금화명령을 한 경우에는, 명문의 규정은 없으나, 채권자가 집행관으로부터 증권을 교부받으려면 현금화명령의 정본을 제시해야 하므로 법원은 채권자에게 현금화명령의 정본을 교부해야 한다.⁴⁶⁵⁾ 채권자는 현금화명령에 기하여 집행관으로부터 증권을 교부받아 현금화명령에 따른 권리를 행사할 수 있게 된다.

2. 추심명령

지시채권의 추심명령에 대하여도 일반 금전채권의 추심명령에 관한 설명이 거의 그대로 적용되지만, 다음과 같은 특유한 점이 있다.

추심명령은 그 명령상 제3채무자로 기재되지 않은 어음·수표 등의 지급의무자에

461) 대법원 1983. 3. 8. 선고 82다카889 판결【판결요지】국세채납으로 인하여 채권압류가 있는 경우에는 채무자는 채권자에게 채무를 지급할 수 없고 오직 소관 세무공무원에만 지급하여야 할 것이고 채납자인 채권자는 그 압류된 채권을 행사할 수 없다고 할 것이므로 그 채권의 지급조로 발행된 약속어음의 수취인인 채권자는 어음금의 지급청구권을 행사할 수 없다.

462) 임순명(주450), 648.; 남기정, 위 실무강제집행법(3), 130.

463) 임순명(주450), 653.; 남기정, 위 실무강제집행법(3), 142.

464) 임순명(주450), 653.

465) 임순명(주450), 654.; 남기정, 위 실무강제집행법(3), 150.

대해서는 효력이 미치지 않는다. 따라서 합동채무를 부담하는 수인의 지급의무자가 있는 때는 그들 전부에 대하여 추심명령을 받을 수 있는데, 이러한 추심명령을 받드시 동시에 받을 필요는 없다.⁴⁶⁶⁾

복수의 채권자를 위하여 수통의 추심명령이 발부된 경우 집행관으로서는 최초에 추심명령정본을 제출하는 채권자에게 증권을 교부하면 된다.⁴⁶⁷⁾

인수되지 아니한 환어음이나 수표의 지급인은 어음·수표상의 채무를 부담하는 것이 아니므로 이들을 제3채무자로 하는 추심명령이 가능한가에 대해서는 견해가 나뉘어진다. 즉 이러한 경우 이부명령(移付命令)보다는 특별현금화명령이 더 바람직하다는 견해와 그러한 지급인에 대한 추심명령을 인정한다고 하더라도 지급인에게 특별히 불리한 결과를 가져오지 않고 또 발행인에 대한 추심명령을 받은 채권자가 지급인에게 지급제시를 할 수 있기 위해서는 위와 같은 지급인에 대한 추심명령도 허용된다는 견해⁴⁶⁸⁾도 있다.

3. 전부명령

어음·수표채권의 일부에 대한 전부명령은 일부의 배서가 무효인 것(어음 제12조 제2항, 수표법 제15조 제2항)과의 관계상 허용되지 않는다.⁴⁶⁹⁾ 다만 집행채권을 초과하는 어음·수표채권 전체에 대한 추심명령이나 특별현금화명령은 가능할 것이다.

지시채권에 대한 전부명령의 효력발생시기는 언제인가.

이에 대하여는 채권자가 명령정본에 기하여 집행관으로부터 증권을 교부받은 때라고 보는 견해⁴⁷⁰⁾도 있는 반면, 그 효력발생시기는 다른 전부명령과 다를 것이 없고 증권의 채권자에의 인도로 채권을 행사하는 자격의 문제에 불과하다는 입장⁴⁷¹⁾도 있다.

전부명령에 기한 지시채권의 이전은 민법상 지명채권양도와 동일한 효력밖에 없으므로 배서에 의한 이전처럼 인적 항변의 절단과 같은 효과는 생기지 아니하고, 집행채무자가 채권자에 대하여 상환의무를 부담하지도 않는다. 또한 채권자가 전부받은

466) 임순명(주450), 655.; 남기정, 위 실무강제집행법(3), 143.

467) 다만 추심명령을 얻어 증권을 교부받은 채권자가 그 추심을 게을리한 때에는 다른 집행력 있는 정본에 의하여 배당을 요구한 채권자가 일정한 기간 내에 추심하도록 최고하고 그에 응하지 않을 경우 집행법원의 허가를 얻어 직접 추심할 수 있다(민집 제250조).

468) 임순명(주450), 656.

469) 임순명(주450), 659.; 남기정, 위 실무강제집행법(3), 146.

470) 임순명(주450), 659.

471) 宮脇幸彦(주43), 187.

채권을 제3자에게 배서양도할 수 없고 지명채권양도의 방법에 의해야 한다.⁴⁷²⁾

합동채무를 부담하는 수인을 상대로 한 전부명령은 그 수인에 대하여 동시에 전부명령을 신청할 때는 가능하지만 그 중 일부에 대하여 이미 전부명령을 받은 때에는 집행채권은 소멸하므로 새로운 전부명령은 허용되지 않는다.⁴⁷³⁾

추심명령과 달리 인수되지 아니한 환어음이나 수표의 지급인을 상대로 하는 전부명령은 허용되지 않는다.⁴⁷⁴⁾

압류의 대상인 지시채권이 배서가 금지된 화물상환증, 창고증권, 선하증권 등 인도증권에 표창된 목적물인도청구권인 경우에는 민사집행법 제245조의 취지에 따라 전부명령은 허용되지 않는다. 이 경우에 종국적인 만족은 목적물을 집행관이 제3채무자로부터 인도받아 유체동산의 현금화방법에 따라서 현금화하고 그 매각대금을 집행법원에 제출하여 배당하도록 하는 민사집행법 제243조의 방법에 의할 수밖에 없기 때문에 집행관이 증권을 점유하여 채권압류의 효력이 발생한 이후에는 유체동산인도청구권에 대한 강제집행절차에 따라 그 절차가 진행되게 된다.

4. 특별현금화명령

예를 들어 어음의 만기가 이례적으로 장기간 이후이거나 또는 제3채무자가 집행채무자에 대하여 반대급부의 인적항변으로 대항할 수 있는 경우나 혹은 어음·수표금액이 집행채권액을 초과하는 경우 등에는 지시채권에 대하여도 특별현금화명령에 의하여 현금화할 수 있을 것이다.⁴⁷⁵⁾

이러한 특별한 현금화명령에 의한 양수인의 지위는 전부명령을 얻은 채권자의 지위와 동일하다고 볼 수 있다.

472) 남기정, 위 실무강제집행법(3), 146.

473) 임순명(주450), 661.

474) 임순명(주450), 661.

475) 임순명(주450), 662.; 남기정, 위 실무강제집행법(3), 148.

제6절 신탁수익권에 대한 집행

I. 서설

우리 신탁법상 신탁이란, 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자) 사이의 신임관계에 기하여 위탁자가 수탁자에게 특정의 재산(영업이나 저작권·산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계를 말한다(신탁법 제2조).

신탁제도는 영미법계에서 생성된 제도로서 미국과 일본을 통하여 국내에 도입되었다. 신탁은 당초 금전신탁을 중심으로 발전하다가 1990년대부터 부동산신탁으로 범위가 확대되고 있다. 신탁의 목적도 재산의 보관·관리·증식으로부터 공격적인 재산증식으로 전환되고 있고, 다양한 금융공학을 활용한 부동산신탁관리와 함께 보험분야로 확장되고 있다.⁴⁷⁶⁾

이와 같은 신탁제도는 설정자가 재산의 운용능력이 없는 수익자를 보호하기 위해 최적화된 방법으로 수익자가 아닌 수탁자에게 재산을 양도하여 운용·관리하게 하여, 수익자에게 이득을 제공하는 제도이다.⁴⁷⁷⁾ 신탁에 있어서 수익자는 수탁자, 신탁재산 등과 함께 기본적인 요소의 하나이고, 신탁행위에 기하여 신탁이익을 향수하는 자를 말한다. 이러한 수익자는 신탁행위의 당사자는 아니지만, 신탁의 목적이 수익자를 위하여 그에게 신탁이익을 누리게 하는 것이므로, 신탁행위 및 그에 의하여 설정된 신탁관계에서 중요한 지위를 갖게 된다. 따라서 수익자, 즉 신탁이익을 취득할 수 있는 권리가 있는 자가 존재하지 않는 신탁은 생각할 수 없을 것이다.⁴⁷⁸⁾

476) 권기혁, “부동산PF에서 신탁을 활용한 시행사 위험통제”, KIS Credit Monitor, 한국신용평가(2012), 4-5.

477) 최수정, “개정 신탁법상의 수익권”, 선진상사법률연구 통권 제59호, 법무부(2012), 140.

478) 이러한 점 때문에 신탁법 제56조 제1항 본문에서, “신탁행위로 정한 바에 따라 수익자로 지정된 자(제58조 제1항 및 제2항에 따라 수익자로 지정된 자를 포함한다)는 당연히 수익권을 취득한다.”고 규정하여, 수익자는 수익의 의사표시를 하지 않더라도 당연히 신탁에 의한 이익을 받도록 하고 있다. 다만 같은 항 단서에서는 이러한 수익자를 정하는 데 있어서 “신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다.”고 하여, 신탁행위로 수익자의 수익의 의사표시를 요구하든지, 조건이나 기한을 정할 수도 있도록 하고 있다. 한편 위와 같은 수익자가 아직 특정되어 있지 않거나 또는 아직 존재하지 않은 경우에는 수익자의 이익을 보호하고 또한 신탁의 실행을 확보하기 위하여 법원은 이해관계인의 청구 또는 직권으로 신탁관리인을 선임하도록 하고 있다(신탁법 제67조 제1항 본문).

근래 우리나라에서도 신탁에 관한 관심이 많이 늘어나고 있고, 또한 법원에 신탁과 관련된 소의 접수도 꾸준히 증가하고 있다. 이러한 상황에서 신탁과 민사집행 문제가 얹히는 경우가 종종 발생한다. 즉 신탁재산에 대하여는 신탁 전의 원인으로 발생한 권리 또는 신탁사무의 처리상 발생한 권리에 기한 경우를 제외하고는 강제집행, 담보권 실행 등을 위한 경매, 보전처분 또는 국세 등 채납처분을 할 수 없는데(신탁법 제22조 제1항), 이에 따라 수익자의 신탁수익권에 대한 집행문제가 중요성을 띠게 되는 것이다. 특히 자익신탁의 경우, 위탁자의 재산에 대해 신탁이 설정되면 그 재산은 수익권으로 전화(轉化)되는 것이므로 이후 위탁자의 채권자들은 수익권에 대한 집행에 집중해야 한다.

II. 신탁수익권의 개념

수익자의 법적 지위가 수탁자에 비해 매우 소극적인 이유로,⁴⁷⁹⁾ 신탁법은 수익자에게 일정한 권리를 부여하여 그 지위를 보호하고자 하는 규정을 두고 있다. 이와 같이 신탁관계에서 수익자가 갖는 고유한 권리를 수익권(Interest of the Beneficiaries)이라고 한다. 이하의 논의를 위하여 위 수익권의 개념을 정립해둘 필요가 있다.

1. 협의의 수익권과 광의의 수익권

가. 협의의 수익권(자익적 권리)

협의의 수익권은 자익권(자익적 권리)라고도 하며,⁴⁸⁰⁾ 수익자가 신탁행위에 따라 이익을 받고 또 신탁이 종료할 때에는 나머지 신탁재산을 받을 수 있는, 즉 신탁재산에 대하여 갖는 기본적인 권리를 말한다. 여기에는 신탁재산의 관리·처분에 따른 이

479) 신탁제도에 있어서 수탁자는 신탁관계의 당사자 중의 하나이지만, 매우 중요한 위치를 차지하고 있다. 즉 신탁에서 수탁자는 신탁재산에 대하여 유일하게 절대적이고 배타적인 관리·처분권한을 보유한 중심적 기관이고(新井誠, 信託法, 有斐閣(2002), 137.), 신탁의 필수적 요소이다. 따라서 신탁재산의 관리·운용은 수탁자가 있어야 비로소 가능하게 된다는 점에서 신탁에서 가장 핵심이라 할 것이기 때문에, 신탁법 제4장(수탁자의 권리·의무)에서 많은 조문을 이에 할애하고 있다.

480) 新井誠(주479), 53. 자익권은 공익권에 대응하는 개념으로 수익자가 신탁재산 또는 수탁자에 대해 기대하는 개인적인 편익과 관련된 권리이다. 통상 신탁재산으로부터의 일정한 급부를 수령할 권리인 급부수령권을 의미하고, 신탁재산에 대한 수익권 소유권을 갖는자로서의 지위에서 1차적으로 파생되는 것이다. 자익권은 급부를 수령할 지위를 나타내는 추상적 자익권과 이미 발생한 구체적으로 발생한 급부청구권, 즉 수익채권으로 구별될 수 있다(이중기, “신탁종료의 효과와 법률관계”, 홍익법학 제8권 제1호, 홍익대학교 법학연구소(2007), 40. 각주 45).

익을 향수할 권리(신탁법 제56조 제1항)인 수익수익권(收益受益權)과 신탁의 종료 후 신탁재산 중 원본의 부분을 향수할 권리(신탁법 제101조)인 원본수익권(元本受益權)이 포함되어 있다.

협의를 수익권은 신탁존속 중의 급부청구권과 신탁종료시의 재산인도청구권으로 나누어 볼 수 있다.

1) 신탁존속 중의 급부청구권

수익자가 신탁계약이 정하는 바에 따라 가지는 일정한 급부를 받을 이익을 수익자의 급부청구권이라고 한다. 이는 수탁자가 부담하는 급부의무에 대한 개념이고, 신탁수익권의 본체라고 할 수 있다. 다만 수익자가 수탁자에게 무엇을 급부청구할 수 있는가는 신탁행위의 내용으로 결정된다. 예를 들면 수익수익권자는 신탁행위에 의하여 수익의 급부를 받는 것으로 정해진 수익자이고, 원본수익권자는 신탁행위에 의하여 신탁재산 그 자체를 받는 것으로 정해진다. 이러한 수익자의 급부청구권은 신탁이라는 이유로 특별히 문제되는 것은 없고, 계약상의 급부청구권으로 취급하면 될 것이다.⁴⁸¹⁾

신탁존속 중의 급부청구권은 이를 기본권인 급부청구권과 지분권인 급부청구권⁴⁸²⁾으로 나누거나 또는 기본적인 수익권과 구체화된 수익권⁴⁸³⁾으로 나눌 수 있다. 기본권인 급부청구권은 지분권인 급부청구권의 기초가 되는 권리이고, 수익자가 신탁행위에서 정한 목적에 따라 일정한 급부를 받는 권리를 말한다. 지분권인 급부청구권은 기본권인 급부청구권에 기하여 이미 구체적으로 발생한 구체적인 급부청구권을 말한다. 기본적인 수익권과 구체화된 수익권의 개념에 대하여는 아래에서 다시 살펴보기로 한다.

2) 신탁종료 후의 신탁재산인도청구권

가) 신탁이 그 종료사유의 발생 또는 위탁자와 수익자의 합의에 의하거나 신탁종료청구에 의한 법원의 신탁종료명령에 의하여 종료하는 경우,⁴⁸⁴⁾ 신탁재산의 귀속문

481) 이근영, “신탁법상의 수탁자의 지위”, 박사학위논문, 경북대학교 대학원(2005. 6.), 200.

482) 이와 같이 분류하는 견해로는, 이근영, “신탁수익권의 소멸시효”, 재산법연구 제24권 제1호, 법문사(2007. 6.), 311.이 있다.

483) 이와 같이 분류하는 견해로는, 임채웅, “신탁수익권에 관한 민사집행의 연구”, 법학 제50권 제4호, 서울대학교 법학연구소(2009), 279.이 있다.

484) 신탁은 신탁종료사유의 발생 또는 위탁자와 수익자의 합의에 의하거나 신탁종료청구에 의한 법원의 신탁종료명령 등으로 종료된다. 신탁종료사유로는, ① 신탁의 목적을 달성하였거나 달성할 수 없게 된 경우(제98조 제1호), ② 신탁이 합병된 경우(제98조 제2호), ③ 제138조에 따라 유한책임신탁에서 신탁재산에 대한 파산선고가 있는 경우(제98조 제3호), ④ 수탁자의 임무가 종료된 후 신수탁자가 취임하지 아니한 상태가 1년간 계속된 경우(제98조 제4호), ⑤ 목적신탁에서

제에 대하여는 신탁법 제101조가 정하고 있다. 즉 신탁이 종료한 경우(다만, 신탁법 제98조 제2호에 따라 신탁이 합병된 경우는 제외한다) 그 신탁재산은 수익자(잔여재산수익자를 정한 경우에는 그 잔여재산수익자)에게 귀속한다(신탁법 제101조 제1항). 다만 신탁행위로 신탁재산의 잔여재산이 귀속될 자(귀속권리자)를 정한 경우에는 그 귀속권리자에게 귀속하며(같은 항 단서), 수익자와 귀속권리자로 지정된 자가 신탁의 잔여재산에 대한 권리를 포기한 경우 잔여재산은 위탁자와 그 상속인에게 귀속한다(신탁법 제101조 제2항). 위탁자가 집행의 면탈이나 그 밖의 부정한 목적으로 신탁을 설정하여 이해관계인의 청구에 의한 법원의 신탁종료명령으로 신탁이 종료하는 경우에는 그 신탁재산이 위탁자에게 귀속한다(신탁법 제101조 제3항).

이때 귀속권리자가 갖는 신탁재산에 관한 권리를 보호해줄 필요가 있는데, 신탁법은 귀속권리자의 신탁재산에 관한 권리보호를 신탁법적 방법으로 구성하고 있다. 즉 신탁이 종료하여도 신탁재산이 귀속권리자에게 이전되기 전에는 신탁은 존속하는 것으로 간주되고, 이때의 귀속권리자는 수익자로 간주하여(신탁법 제101조 제4항) 귀속권리자를 보호하고 있다. 이는 귀속권리자를 수익자로 하는 신탁을 상정하여 '귀속권리자를 위한 신탁'이 발생한다고 간주하는 것인데, 이를 '귀속권리자를 위한 법정신탁'이라고 한다.⁴⁸⁵⁾ 이는 신탁재산이 인도되면 종료하게 된다.

나) 이와 같이 신탁법상 수익자의 개념과 귀속권리자의 개념은 구별된다. 신탁의

신탁관리인이 취임하지 아니한 상태가 1년간 계속된 경우(제98조 제5호), ⑥ 신탁행위로 정한 종료사유가 발생한 경우(제98조 제6호) 등이 있고, ⑦ 수탁자의 지위와 수익자의 지위에 혼동에 의한 종료(제36조)도 이에 해당한다. 또한 위탁자와 수익자는 합의하여 언제든지 신탁을 종료할 수 있고(제99조 제1항, 다만 위탁자가 존재하지 않는 경우에는 불가), 위탁자가 신탁이익의 전부를 누리는 신탁(완전한 자익신탁)은 위탁자나 그 상속인이 언제든지 종료할 수 있다(제99조 제2항). 그리고 신탁행위 당시에 예측하지 못한 특별한 사정으로 신탁을 종료하는 것이 수익자의 이익에 적합함이 명백한 경우에는 위탁자, 수탁자 또는 수익자가(제100조), 위탁자가 집행의 면탈이나 그 밖의 부정한 목적으로 신탁을 설정한 경우에는 이해관계인이(제3조 제3항) 각 법원에 신탁의 종료를 청구할 수 있다(신탁종료명령청구권). 그 밖에 통상적인 경우는 아니지만, 사해신탁이 취소된 경우에도 신탁이 종료한다(제8조).

485) 대법원 2012. 7. 12. 선고 2010다1272 판결【판결요지】...신탁행위로 달리 정하였다는 등 특별한 사정이 없는 한, 위탁자의 해지청구 등으로 신탁이 종료하더라도 수탁자가 신탁재산의 귀속권리자인 수익자나 위탁자 등에게 저작재산권 등 신탁재산을 이전할 의무를 부담하게 될 뿐 신탁재산이 수익자나 위탁자 등에게 당연히 복귀되거나 승계되는 것은 아니고, 신탁재산을 이전할 때까지는 수탁자는 신탁사무의 종결과 최종 계산을 목적으로 하는 귀속권리자를 위한 법정신탁의 수탁자로서 그와 같은 목적 범위 내에서 신탁재산을 계속 관리할 권한과 의무를 부담하며, 귀속권리자는 신탁수익권 형태로서 신탁재산 등 잔여재산에 대한 권리를 보유하게 될 뿐이다. 나아가 구 신탁법에는 신탁 종료 시 수탁자의 청산의무에 관하여 아무런 규정이 없으므로, 신탁행위로 달리 정하였거나 해당 신탁 취지 등에 의하여 달리 볼 수 없는 한 수탁자는 청산의무를 부담하지 않는데, 수탁자가 신탁재산에 관하여 체결한 쌍무계약에 관하여 아직 이행을 완료하지 아니한 때에는 계약을 귀속권리자에게 인수시킬 수도 있는 것이고, 신탁이 종료하였다고 하여 반드시 계약을 해지하는 등으로 이를 청산하여야 하는 것은 아니다.

종료에서 귀속권리자의 개념과 누가 귀속권리자인가는 잔여재산의 인도절차에서 중요한 의미를 가지고 있다. 여기서 귀속권리자란, 신탁존속 중에는 수익자의 권리를 행사할 수 없으나, 신탁종료시 잔여재산이 자신에게 귀속하는 것에 대한 기대권을 갖는 자라는 의미로 사용되는 것이다.

귀속권리자는 신탁종료사유발생으로부터 청산이 완료될 때까지 사이에 간주수익자(看做受益者)로서 포괄적인 수익자의 권리를 갖게 되므로(신탁법 제101조 제4항), 예를 들어 수탁자가 신탁위반행위를 한 경우에는 그것에 대하여 수익자로서의 권리를 행사할 수 있다.

나. 광의의 수익권

1) 광의의 수익권은 수익자의 지위에서 누리는 여러 가지의 권리와 권능을 총칭하는 것으로서 포괄적인 수익자의 권리를 말한다.⁴⁸⁶⁾ 즉 수익자의 급부청구권(협의의 수익권)과 이를 보호하기 위하여 신탁재산의 적절한 관리를 확보하기 위하여 수익자에게 부여된 감독적 권능을 그 핵심으로 하는 것으로서 이를 수익자의 ‘신탁감독적 기능’이라고 할 수 있다.⁴⁸⁷⁾ ⁴⁸⁸⁾

다만 이러한 신탁감독적 기능은 주식회사의 주주와 비교해볼 때, 신탁의 구조상 수익자에게 주주 정도로 신탁에 대한 감독을 요구하고 있지는 않다. 신탁은 수탁자에게 엄격한 신뢰의무를 부과하는 등 중한 책임을 지우고 이로써 신탁의 사무가 적절하게 행해지도록 하고 있다. 이는 이사가 널리 재량권을 가지고 광범위한 활동을 하며, 그에 대하여 주주가 이사를 모니터링하는 구조를 취하고 있는 주식회사와 근본적으로 다르다. 이와 같은 이유로 신탁이 구조적으로 간단하고, 비용이 들지 않으며 유연하다는 평가를 받게 되는 것이다.⁴⁸⁹⁾

2) 이러한 수익자의 신탁감독권능에 해당하는 것으로는, ① 법원에 대한 수탁자 해임청구권(신탁법 제16조 제3항), ② 수탁자의 임무종료시 신수탁자를 특정하지 않았을 때 법원에 대한 신수탁자 선임청구권(신탁법 제21조 제2항), ③ 신탁사무처리에 관한 서류열람청구권 및 수탁자에 대한 설명청구권(신탁법 제40조 제1항), ④ 수탁자 경질에 따른 사무인계 입회권과 승인권(신탁법 제55조), ⑤ 신탁행위 당시에 예측하

486) 道垣内弘人/大村敦志/瀧澤昌彦 編, 信託取引と民法法理(初版), 有斐閣(2004), 276.

487) 能見善久, “現代信託法講義(7)”, 信託 208号(2001. 11.), 50.

488) 이를 ‘자익권과 공익권으로 된 복합적 내지 포괄적 권리’라고 하거나[新井誠(주479), 53.] 또는 ‘수익권의 급부청구권(자익권)’이라고도 한다.

489) 能見善久(주487), 51.

지 못한 특별한 사정으로 신탁을 종료하는 것이 수익자의 이익에 적합함이 명백한 경우 법원에 대하여 신탁의 종료를 청구할 수 있는 권리(신탁법 제100조, 신탁종료명령 청구권) 등이 있다.

그리고 종래 다수의 견해는, 신탁재산 강제집행 등에 대한 이의신청권(신탁법 제22조 제2항), 신탁위반법률행위의 취소권(신탁법 제75조 제1항), 신탁위반을 이유로 인정되는 원상회복 또는 손해배상청구권(신탁법 제43조 제1항), 수탁자의 파산시 신탁재산에 대한 수익자의 환취권(신탁법 제24조) 등을 협의의 수익권으로 분류하고 있으나, 이는 모두 급부청구권을 보호하기 위하여 인정되는 수단적 권리라고 할 수 있으므로, 이들 전부를 광의의 수익권으로 보는 것이 타당할 것이다.⁴⁹⁰⁾ 또한 수탁자에 대한 유지청구권(신탁법 제77조)과 신탁의무이행청구권도 신탁감독권능의 범주에 포함시킬 수 있을 것이다.

2. 원본수익권(元本受益權)과 수익수익권(收益受益權)

종래 강화상 또는 신탁실무상 원본수익권이라는 용어가 사용되어 왔고, 이는 대체로 ‘신탁종료시에 잔여신탁재산을 수수하는 권리’라고 설명되었다. 이러한 원본수익권은 수익수익권에 대응하는 개념이다. 예를 들어 위탁자 甲이 2018. 1. 1. 수탁자 乙에게 그의 부동산을 신탁하고 10년간 그 수익에서 월 200만 원을 수익자인 丙에게 지급하며, 매월 발생하는 수익 중 200만 원을 넘는 부분은 신탁재산에 편입하고, 10년 후 신탁기간이 종료되면 잔존 신탁재산을 丙에게 인도하기로 하는 계약을 체결하였다면, 이때 수익자 丙이 월 200만 원씩 받을 권리가 수익수익권이고, 잔존 신탁재산을 받을 권리가 원본수익권이라고 할 수 있다.

원본수익권의 개념은 엄밀히 말하자면 신탁종료 후의 문제이므로 이는 귀속권리자의 권리가 되고, 원래 신탁상의 수익권의 문제는 아니다. 그러나 원본 자체의 교부를 의미하는 원본수익권의 개념을 반드시 신탁종료시를 전제로 할 필요는 없다. 신탁관계가 유지되고 있을 때에도 신탁재산의 원본을 분할하여 수익자에게 교부하도록 할 수 있기 때문이다. 따라서 원본수익권을 ‘수익자의 지위에서 신탁재산을 수수할 권리’라고 봄이 타당할 것이다.^{491) 492)}

490) 이근영, “신탁법상 수익자의 수익권의 의의와 수익권포기-신탁법 제42조 제3항을 중심으로-”, 민사법학 제30호, 한국사법행정학회(2005. 12.), 188-189.

491) 임채웅(주483), 279.

492) 실무상 에스크로(Escrow, 상거래시에 판매자와 구매자 사이에 신뢰할 수 있는 중립적인 제3자가 중계하여 금전 또는 물품을 거래하도록 하는 것 또는 그러한 서비스를 지칭한다)를 할 때에 반드시 신탁을 통하는 것은 아니지만, 신탁을 통하여 에스크로를 할 경우 수탁자는 일정한 조건이

3. 기본적인 수익권과 구체화된 수익권⁴⁹³⁾

가. 수익자가 갖는 권리 중 금전 또는 재산의 급부와 관련되는 것들, 즉 민사집행의 대상이 될 수 있는 것들을 분석해보면, ① 수익권의 여러 모습 전체를 포괄하는 권리로서의 수익권 그 자체, ② 그 개별내용으로 수탁자가 지급하여야 할 의무가 이미 발생한 수익금에 대한 권리, ③ 앞으로 신탁종료시까지 지급받을 권리, ④ 신탁이 종료하고 나서 귀속권리자로서 남은 신탁재산을 교부받을 권리가 있다.

앞의 예에서 만일 수탁자 乙이 수익자 丙에게 아무 것도 지급하지 않은 상태에서 2019. 1. 1.이 되었다고 할 경우, 그때까지 이미 발생한 1년분 수익금 2,400만 원이 위 ②의 수탁자가 지급하여야 할 의무가 이미 발생한 수익금에 대한 권리고, 이를 ‘이미 구체화된 수익권’이라고 말할 수 있으며, 이후 신탁종료시까지 매월 200만 원씩 지급받을 권리를 위 ③의 앞으로 신탁종료시까지 지급받을 권리라고 할 수 있는데, 이를 ‘앞으로 구체화될 수익권’이라고 지칭할 수 있다. 이와 같이 ‘이미 구체화된 수익권’과 ‘앞으로 구체화될 수익권’을 합하여 ‘구체화된 수익권’이라고 부른다. 그리고 위 ①의 수익권의 여러 모습 전체를 포괄하는 권리로서의 수익권 그 자체는 이를 ‘기본적인 수익권’이라고 부를 수 있다. 따라서 수익권 자체와 그 수익권 자체의 내용 중 일부이면서 동시에 신탁이 유지되는 동안 신탁계약의 내용에 따라 수익자에게 교부되는 것에 대한 권리를 ‘구체화된 수익권’이라고 할 수 있다. 기본적인 수익권

충족될 때까지 해당 금원을 보유하고 있고, 수익자에게 금원을 지급하지 않는다. 그러다가 조건이 성취되면 일시에 위 금원을 수익자에게 교부한다. 예를 들어 다수의 담보권·가압류가 설정되어 있고 토지거래허가를 받아야 하는 甲의 토지를 乙이 500억 원에 매수하고 그 매수대금의 상당액을 금융기관으로부터 차용해 지급해야 하는 경우, 매도인 甲은 매매대금을 모두 수령해야 매수인에게 소유권을 이전해 줄 것이고, 매수인은 토지에 설정된 다수의 담보권이나 가압류등기 등이 말소된 깨끗한 토지를 넘겨받아야 할 뿐만 아니라 토지거래허가도 받아야 할 것이다. 그러나 이를 위해서는 乙이 甲에게 미리 상당한 돈을 제공해야 할 필요가 있는데, 매수인 및 대출금융기관으로서는 계약금이나 중도금으로 매도인에게 미리 지급하는 거액의 매매대금이 그러한 목적으로 사용될 것인지, 토지거래허가를 받지 못할 경우의 지급대금 회수를 생각하면 마음을 놓을 수 없다. 이때 甲이 신탁회사에 위 부동산을 신탁하면서 이러한 목적에 맞는 신탁계약 조항을 마련하고, 매수인 乙도 신탁계약상의 권리를 확보한다면 甲과 乙은 원만하게 이 거래를 성사시킬 수가 있게 된다. 이러한 경우에 이용되는 것이 에스크로제도이다.

에스크로업자의 서비스는 에스크로재산(신탁재산)을 운용하여 수익을 내는 것이 아니라 위탁자의 이익을 위하여 일정시기까지 그 재산을 보유해주는 것이다. 이와 같이 신탁을 통한 에스크로에서는 신탁수익자의 수익권과 에스크로계약 자체가 추구하는 이익이 일치하지 않게 된다.

이와 같은 에스크로에 있어서는 원본수익권만 있고 수익수익권은 존재하지 않는 것이 되므로 신탁수익권 그 자체의 집행에 관심을 돌려야 될 것이다.

493) 기본적인 수익권과 구체화된 수익권의 개념구분에 관해서는, 임채웅(주483), 279-281, 참조

과 구체화된 수익권은 개념상으로 구분되나 후자는 전자에 완전히 포함되는 것이다. 이는 원본과 이자의 관계에 있는 것도 아니다.⁴⁹⁴⁾

또한 위 ④ 신탁이 종료하고 나서 귀속권리자로서 남은 신탁재산을 교부받을 권리는 앞서 본 ‘원본수익권’의 모습이다. 그런데 신탁이 종료되고 나면 종래의 신탁은 일종의 법정신탁으로 바뀌게 되고, 귀속권리자는 그 법정신탁의 수익자로 간주되므로 신탁종료 전후의 수익자의 지위 및 수익권의 의미가 달라지게 된다. 신탁이 종료된 후 실질적으로 종래의 신탁관계가 그대로 유지되는 것으로 볼 수도 있지만 그러더라도 여하튼 법적으로는 원래의 수익권은 아니다.

나. 앞서 본 원본수익권과 수익수익권 개념이 여기에서 말하는 기본적인 수익권 및 구체화된 수익권의 개념과 일치하는 것은 아니다. 기본적인 수익권은 수익권을 이루는 모든 권리를 합한 개념으로서 수익권 그 자체를 의미하고, 이에 원본수익권, 수익수익권, 구체화된 수익권 등이 모두 포함된다. 또 수익수익권이라고 하면 원칙적으로 신탁재산의 운용으로부터 발생하는 수익에 터잡은 수익권을 의미하는 것으로서 이는 구체화된 수익권에 포함되나, 구체화된 수익권에 반드시 그러한 경우만 있는 것은 아니다. 예컨대 신탁원본으로 현금 3,000만 원이 교부되고, 그 신탁재산에 대한 운용 없이 월 200만 원씩 수익자에게 교부하기로 하는 경우에는 이를 수익수익권이라고 하기 어렵지만 이는 구체화된 수익권에는 포함되는 개념이다.

다. 이하에서 신탁수익권에 대한 집행의 문제를 접근해 들어갈 때에 위와 같은 기본적인 수익권과 구체화된 수익권의 개념이 유용하므로 이에 따라 서술하기로 한다.

4. 수익권과 수익채권

가. 현행 우리 신탁법은 일본 신탁법을 계수하여⁴⁹⁵⁾ 수익채권의 개념을 도입하고 이를 수익권과 구분하고 있다.

494) 이러한 것은 다양한 권리의 묶음인 저작권과 그 내용을 이루는 개별권리의 관계와 비교될 수 있다. 특정 저작권 자체가 1단위의 재산권이 되면서도 동시에 그 내용을 이루는 개개의 권리도 또 1단위의 재산권이 될 수 있는 것과 같은 것이다.

495) 일본의 개정 전 신탁법은 영미의 신탁법리를 기본으로 하고 있다. 일본은 1882년 인도신탁법과 1872년 캘리포니아주 민법 중 신탁에 관한 규정을 참조하여 이를 제정하였다(이연갑, “신탁법상 수탁자의 의무와 권한”, 선진상사법률연구 통권 제48호, 법무부(2009), 31.). 이러한 규정은 현행 신탁법과 거의 유사하다고 할 수 있다. 일본은 2006년 12월에 신탁법을 271개 조문으로 전면 개정하였다. 일본 개정신탁법의 경우 그 개정 내용이 구법(구신탁법)과 비교할 때, 새로운 법률의 제정에 가까울 정도로 질적, 양적 증가가 이루어져 이를 ‘신신탁법(新信託法)’이라고도 한다.

이에 따르면 수익자가 수탁자에게 신탁재산에 속한 재산의 인도와 그 밖에 신탁 재산에 기한 급부를 요구하는 청구권이 바로 '수익채권'이다(신탁법 제62조).⁴⁹⁶⁾ 즉 수익채권이란 '수익자의 권리로서 신탁재산에 속한 재산의 인도와 그 밖에 신탁재산에 관한 급부와 관련된 채권'을 말한다. 그리고 우리가 받아들인 일본 신탁법 제2조 제7항이, '이 법률에서 「수익권」이란, 신탁행위에 기초하여 수탁자가 수익자에 대해 부담하는 채무로서 신탁재산에 속한 재산의 인도와 그 외 신탁재산에 관한 급부와 관련된 채권(즉 수익채권) 및 이것을 확보하기 위하여 이 법률의 규정에 의하여 수탁자와 그 외의 자에게 일정한 행위를 구할 수 있는 권리를 말한다'고 규정하고 있는 것에 비추어 보면, 수익권에는 위와 같은 수익채권 외에 그 밖의 권리가 포함되는 것이다. 따라서 수익채권이란 수익권 중에서 재산의 인도나 급부를 구할 수 있는 권리를 말하고, 그것이 수익권과 다른 별개의 것은 아니다.

나. 우리 신탁법은 수익자와 귀속권리자의 개념을 구분하고 있다. 수익자가 귀속권리자가 될 수도 있으나, 그 지위는 원래의 신탁에서의 수익자가 아니라 신탁종료로 인하여 발생하는 법정신탁의 간주수익자인 귀속권리자이다. 따라서 수익자가 귀속권리자로 되는 경우라도 이론적인 면에 있어서 이때의 귀속권리자로서의 권리는 원래의 수익권이라고 할 수 없다.⁴⁹⁷⁾

그런데 현행 신탁법에서 앞서 본 수익채권이 그 내용으로서 잔여재산의 급부를 내용으로 할 수 있으므로, 이에 의할 경우 수익자가 신탁행위에 의하여 귀속권리자가 되는 때에는 신탁행위에 따른 수익권의 일부가 되어버린다. 또 신탁법은 잔여재산수익자와 귀속권리자를 구분하고 있고(신탁법 제101조 참조), 반드시 잔여재산수익자가 일반적인 수익자의 지위를 겸하여야 할 필연성도 없어 보인다. 따라서 신탁행위에서 일반수익자와 잔여재산수익자를 따로 둘 수도 있을 것이다. 만일 잔여재산 전부가 잔여재산수익자에게 가는 것이 아니라면, 잔여재산수익자와 귀속권리자 둘 다 있는 경우도 상정할 수 있고, 한편 귀속권리자도 신탁행위에 의하여 지정될 수 있다.⁴⁹⁸⁾

496) 한편 신탁법은 '신탁채권은 수익채권에 우선한다'고 규정(제62조)하고, 또 '수익채권의 소멸시효는 수익자가 수익자로 된 사실을 알게 된 때부터 진행하되, 채권의 예에 따른다'고 규정(제63조 제1항, 제2항)하고 있다.

497) 따라서 현행법하에서 수익권을 압류한다고 할 때 단순히 수익권만을 표시하면 원래의 신탁(보통 계약신탁)의 수익권만을 압류하는 것으로 될 우려가 있으므로, 수익자가 귀속권리자가 되는 경우 그 귀속권리자의 권리도 압류하기 위해서는 그 권리도 압류함을 명백히 표시함이 바람직하다.

498) 이렇게 되면 잔여재산수익자와 귀속권리자를 구분하는 것이 문제로 될 수 있다. 왜냐하면 잔여재산수익자가 반드시 신탁행위에 의하여 특정되어야 하는 것은 아니고, 반대로 귀속권리자를 신탁행위로 특정하는 것도 가능할 것이기 때문이다. 결국 이들의 차이는 그 지정된 자 또는 지정될 자가 신탁이 존속하는 동안에 수익자의 지위를 누릴 수 있는가(잔여재산수익자), 혹은 그렇지 않은가(귀속권리자)의 여부에 있다고 볼 수 있다(임재웅(주483), 285. 참조).

이와 같이 이해한다면, 신탁이 종료된 후 청산이 완료될 때까지의 법률관계의 성격에도 변화가 있다고 보아야 한다. 즉 종래까지는 신탁이 일단 종료되면 그 이후로는 법정신탁이 성립되고 귀속권리자가(간주)수익자가 되는 것으로 이해하였으나, 수익채권제도 하에서는 잔여재산수익자가 있는 경우에는 원래의 신탁관계가 그대로 유지되는 것이고, 귀속권리자에 대하여는 여전히 법정신탁이 성립하는 것으로 보아야 할 것이다. 결국 수익채권개념의 도입으로 수익권이 의미하는 범위가 확장되게 되며, 따라서 수익권에 대해 집행을 할 경우에도 이에 맞추어 그 대상물을 엄격히 표시할 필요가 있게 된다.⁴⁹⁹⁾

5. 수익권과 주주의 권리

신탁의 수익자의 입장에서 보면 신탁재산의 운용에 관하여 수익을 얻는 한편, 그로 인한 책임은 수익권의 상실을 한도로 하는 것이어서 일종의 책임제한효과를 얻게 된다. 이러한 점에서 신탁은 회사와 비교되고, 법제도로써 어느 정도는 경쟁관계에 있다. 애초에 신탁이라는 법전통이 없는 나라에서는 신탁이 활발하게 운용되는 나라에서 신탁이 담당하는 역할을 회사를 포함한 법인이 이를 담당할 수 있다. 우리의 경우 신탁과 법인을 활발하게 비교검토하고 있지는 않으나, 양 제도를 각각 발달시켜가는 한편, 두 제도 사이에 균형을 유지할 필요도 있을 것이다. 통상 신탁은 주식회사에 비해 구조적으로 간단하고 비용이 들지 않으며 유연하다는 평가를 받고 있다.⁵⁰⁰⁾

신탁에 있어서 수익권 자체는 주식회사에서 주주의 권리에 해당되며, 수익자는 주주의 지위에 있다고 비교해볼 수 있다. 종래 신탁에 관련된 집행문제는 주로 수익자가 정기적으로 지급받는 수익에 관심이 집중되어 왔다. 그런데 이를 주식회사와 비교하면, 주주의 권리 자체가 아니라 주주가 매 회기마다 배당받는 배당금에 대한 집행만이 주로 문제되어 왔다고 할 수 있다. 그 밖에는 주로 외면상 예금과 비슷한 형태로 은행에 예치되어 있는 신탁원금에 대한 집행이 문제되었다. 이는 신탁재산에 대한 집행이라 할 수 있으며, 수익권 자체에 대한 집행은 아니다.

종래 수익권 자체에 대한 집행이 별로 문제되지 않은 것은, 그러한 수익권을 처분하여 환가하는 것이 쉽지 않았기 때문이다. 활발한 시장이 형성되어 있지 않으므로 제3자에 대한 매각도 쉽지 않다. 따라서 눈에 보이는 금전형태로 존재하고 있는 신탁재산

499) 수익채권의 개념이 도입되었다고 하여 집행과 관련하여 실질적으로 큰 변화가 있다고는 보이지 않으나, 종래 귀속권리의 일부였던 것이 수익권으로 변화됨에 따라 신탁재산에 대한 집행가능성에 영향을 줄 가능성이 있다. 이는 신탁이 종료되지 않은 상태에서 귀속권리자가 귀속권을 보전채권으로 하여 신탁재산에 대해 가처분을 할 수 있는가라는 문제와 관련되어 있다. 이에 대하여 대법원 2008. 10. 27.자 2007마389 결정은 이와 같은 가처분이 가능하다고 볼 여지를 남겨두고 있다.

500) 能見善久(주487), 51.

이나 정기적인 금원 형태로 지급되는 수익권에만 주로 관심이 집중되었던 것이다.

그러나 신탁수익권 그 자체도 재산으로서 가치있는 것이므로 집행의 대상에서 제외될 수 없다. 게다가 앞서 본 에스크로(Escrow)의 경우와 같이 정기적인 금원 형태로 지급되는 것이 없는 경우에는 신탁수익권 그 자체의 집행에 관심을 돌릴 수밖에 없다.

6. 부동산담보신탁과 우선수익권

가. 신탁을 설정하는 목적은 다양하나, 그 중 채권의 담보를 위하여 설정하는 신탁을 담보신탁이라고 한다. 신탁은 구체적인 수요에 따라 얼마든지 다양하게 설정할 수 있기 때문에 담보신탁은 담보를 위하여 설정된 신탁을 의미할 뿐이며, 부동산담보 신탁도 담보목적으로 부동산을 신탁재산으로 하는 신탁을 설정하는 것이고, 그 밖의 내용들에 대하여는 열려 있는 개념이라고 볼 수 있다.⁵⁰¹⁾

채권자가 자신의 채권을 확보하기 위하여 채무자 또는 제3자가 제공하는 부동산을 담보로 활용하는 방법은 다양하다. 특히 대규모 개발사업에 있어서 여러 채권자가 개재되는 때 신탁은 유용한 담보수단이 된다. 단순히 신탁수익권에 질권을 설정하는 외에 담보권을 신탁하면서 채권자를 수익자로 정하거나 보다 많은 경우에는 채권자를 우선수익자로 하는 부동산담보신탁을 설정하는 것이다.

나. 부동산담보신탁계약의 구조⁵⁰²⁾는, 채무자가 자신의 부동산에 대하여 채무자가 자신의 부동산에 대하여 신탁을 설정하면서 채권자를 우선수익자로, 자신을 수익자로 정하고, 위탁자의 채무불이행시에 신탁재산을 매각한 대금으로부터 채권자가 우선적으로 만족을 얻으며, 위탁자 겸 수익자는 그 잔여분을 수익금부로 받는 것이다.⁵⁰³⁾

501) 최수정, “부동산담보신탁상 우선수익권의 성질과 우선수익권질권의 효력”, 인권과정의(Vol. 470), 46.

502) 부동산담보신탁의 구조에 관한 학설로는, ① 위탁자가 자신의 부동산을 신탁하고 발급받은 수익권증서를 금융기관에 담보로 제공하고, 신탁회사는 위탁자의 채무불이행시에 부동산을 처분하여 금융기관에 변제해 주는 신탁이라는 견해[최동식, 신탁법, 법문사(2006), 48.], ② 채무자인 위탁자가 채권자인 수익자를 위하여 수탁자에게 부동산의 소유권을 이전하고 채무불이행시에 수탁자가 담보목적의 부동산을 처분하여 그 매각대금으로 수익자인 채권자에게 반환하는 방법의 신탁이라는 견해[김상용, “부동산담보신탁제도개발의 필요성과 법적 문제점 검토”, 「경영법률」제5집, 한국경영법률학회(1992), 663.; 고일광, “부동산신탁에 관한 회생절차상 취급-부동산담보신탁의 경우를 중심으로-”, 「사법」제9호, 사법발전재단(2009), 67.], ③ 채무자 소유의 부동산을 수탁자에게 신탁하면 수탁자는 우선수익자인 채권자 및 보통수익자인 채무자를 위하여 신탁재산을 보관, 관리하고 채무불이행시에 신탁재산을 처분하는 형태라는 견해[이중기, 신탁법, 삼우사(2007), 257.], ④ 담보신탁의 정의로서 담보와 관련된 모든 종류의 신탁을 최광의의 담보신탁이라고 하고, 신탁형식과 담보목적 외의 목적 유무를 불문하고 담보를 목적으로 채권자를 수익자로 하여 설정한 신탁을 광의의 담보신탁, 담보만을 목적으로 채권자를 수익자로 하여 설정한 신탁을 협의의 담보신탁이라고 구분하는 견해[임재웅, “담보신탁의 연구”, 인권과정의 378호(2008. 2), 126.] 등이 있다.

503) 대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결 참조.

이러한 구조하에서 신탁자는 신탁존속 중 신탁법 및 신탁계약의 정함에 따라 신탁재산을 소유, 관리하게 되고, 위탁자 겸 수익자는 자신의 부동산을 수탁자에게 양도함으로써 소유권을 상실하지만, 수익권의 내용으로서 신탁종료 후 잔여신탁재산을 반환받거나 신탁존속 중 신탁재산을 사용, 수익할 수도 있다.⁵⁰⁴⁾

또한 채권자는 만일 채무가 변제되지 않을 경우 우선수익권의 내용으로서 수탁자에게 신탁재산의 환가를 요구하고 그 대금으로부터 수익금부의 형태로 채권의 만족을 얻을 수 있다. 이후 잔여재산은 신탁상 정함에 따라 귀속되고 신탁관계는 소멸한다. 그러나 우선수익자인 채권자의 채권이 변제되면 신탁상 우선수익권의 존속기간은 위탁자가 채무를 전부 변제할 때까지로 정하는 것이 일반적이므로 이러한 정함에 따라 채권자가 채권의 만족을 얻은 시점에 소멸한다. 그리고 당해 신탁은 통상 신탁상 정한 바에 따라(신탁법 제98조 제6호) 또는 신탁목적의 달성에 의해(신탁법 제98조 제1호) 종료하게 된다. 다만 신탁의 종료원인이 발생한다고 하더라도 신탁을 둘러싼 법률관계가 동시에 소멸하는 것은 아니며, 신탁계약이나 신탁법에 따라 수탁자가 신탁사무를 종결하고 잔여재산을 수익자에게 귀속시키는 등 일련의 절차가 마무리될 때까지는 법정신탁이 존속한다(신탁법 제101조 제4항).

다. 부동산담보신탁상 우선수익권⁵⁰⁵⁾의 법적 성질에 관하여는 여러 견해가 있지만, 판례는 기본적으로 부동산담보신탁상 우선수익권이 경제적으로 금전채권에 대한 담보로 기능하지만 금전채권과는 독립한 신탁계약상의 별개의 권리라고 보고 있다.⁵⁰⁶⁾

한편 위탁자가 금전채권을 담보하기 위하여 금전채권자를 우선수익자로, 위탁자를 수익자로 하여 위탁자 소유의 부동산을 신탁법에 따라 수탁자에게 이전하면서 채무불이행 시에는 신탁부동산을 처분하여 우선수익자의 채권 변제 등에 충당하고 나머

504) 예를 들어 양도담보의 경우 양도담보설정자는 목적물의 소유권을 채권자에게 이전하지만, 많은 경우 양도담보계약상 목적물을 점유, 사용, 수익한다. 이것이 교환가치를 목적으로 하는 양도담보권자의 의사와 사용가치를 유지하고자 하는 양도담보설정자의 의사에 부합하기 때문이다. 부동산담보신탁에서도 채권자는 신탁재산의 교환가치를 우선수익권을 통해 확보하고자 한 것이고 또 수익권의 내용은 신탁상 정함에 따르므로, 신탁계약상 위탁자 겸 수익자에게 수익수익권을 허용하는 데에는 장애가 없다. 이와 달리 채권자에게 수익수익권을 수여하고 그 부분만큼을 채무변제에 충당하는 것으로도 정할 수 있다.

505) 신탁의 경우 일반적으로 위탁자가 수익자가 되고, 대출기관이 제1순위 우선수익자, 건설사가 제2순위 우선수익자가 된다. 위탁자는 대개의 경우 채무자가 되는데, 위탁자가 자신의 채무를 담보하기 위하여 자신이 가지는 수익권을 양도하거나 질권을 설정하기도 하고 채권자에게(후순위)우선수익권을 설정해 주기도 한다.

506) 대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결; 대법원 2017. 9. 21. 선고 2015다52589 판결 등

지를 위탁자에게 반환하기로 하는 내용의 담보신탁을 해 둔 경우, 특별한 사정이 없는 한 우선수익권은 경제적으로 금전채권에 대한 담보로 기능할 뿐 금전채권과는 독립한 신탁계약상의 별개의 권리가 되므로, 이러한 우선수익권과 별도로 금전채권이 제3자에게 양도 또는 전부되었다고 하더라도 그러한 사정만으로 우선수익권이 금전채권에 수반하여 제3자에게 이전되는 것은 아니고, 금전채권과 우선수익권의 귀속이 달라졌다는 이유만으로 우선수익권이나 이를 목적으로 하는 권리질권이 소멸하는 것은 아니라는 것이 판례의 입장이다.⁵⁰⁷⁾

그러나 이에 대하여는, 채권 또는 우선수익권 일방의 양도나 전부에 의하여 양자가 분리되는 경우 일반적으로 타인에게 속한 채권의 만족을 위한 권리를 제3자가 보유했을 경제적인 의미를 찾을 수 없고, 당사자간의 법률관계를 불명확하게 만들어 분쟁을 야기할 수 있으며, 우선수익권이 경제적으로 채무의 이행을 확보하기 위한 것인 만큼 채권자와 우선수익자가 일치하거나 적어도 우선수익권이 채무의 이행 확보라고 하는 기능을 수행하는 법률관계가 전제되어야 하므로, 우선수익권이 채권과 분리되면 별도의 정함이 특단의 사정이 없는 한 신탁은 목적달성불능으로 종료하고, 그에 따라 우선수익권도 소멸한다고 보아야 하며, 나아가 우선수익권에 대하여만 질권을 설정한 경우에는 질권설정자가 채권자의 지위를 유지하는 때에만 그 효력이 인정되어야 하므로 만일 채권이 전부됨으로써 우선수익권이 분리되었다면 우선수익권 자체가 소멸하는 결과 우선수익권질권도 소멸한다고 보아야 한다면서 위 판례를 비판하는 견해가 있다.⁵⁰⁸⁾

III. 신탁수익권의 법적 성질

1. 신탁수익권의 법적 성질을 어떻게 볼 것인가에 관하여, 일본에서는 ① 채권설,⁵⁰⁹⁾ ② 비채권설,⁵¹⁰⁾ ③ 물적 권리설,⁵¹¹⁾ ④ 병존설⁵¹²⁾ 등이 나타나고 있다.

507) 대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결; 대법원 2017. 9. 21. 선고 2015다52589 판결 등

508) 최수정(주501), 58-59.

509) 植田 淳, “改正信託法の下での受益者の權利 : いくつかの側面に関する考察”, 神戸外大論叢 61(5), 神戸市外国語大学研究会(2010), 23.

510) 岩田 新, 信託法新論(1993), 99-100.

511) 西宮和夫, 信託法(1989), 78.; 金融法委員會, “信託受益權に対して設定された質權の効力”, 金融法委員會(2004), 2.

512) 王涌, “信託法と物權法の関係について : 民法における信託法の問題”, 特集 雇用と社会保障の交錯(2009), 164.

가. 채권설은 수익자는 수탁자에 대한 채권(금부청구권)만을 가질 뿐이라고 한다. 수탁자에게 재산권이 이전되면 신탁재산의 관리·처분권과 명의까지 수탁자에게 모두 이전하며 수탁자는 신탁재산을 수익자의 이익을 위하여 관리하여야 하는 채권적 제약을 받으며, 따라서 수익자는 단지 수탁자에 대하여 신탁재산으로부터 일정한 수익을 받거나 신탁종료시 신탁재산의 반환을 청구할 수 있는 채권을 가질 뿐이고, 수탁자가 신탁재산을 임의로 처분할 경우 수익자를 물권적으로 보호할 근거를 설명하기 곤란하게 되기 때문에 신탁법에 규정을 두어 특별한 보호를 부여하고 있다고 한다.⁵¹³⁾ 그러나 채권설에 대하여는 채권의 효력만으로 설명할 수 없는 수익권 행사의 효과를 법률이 인정한 예외로 처리할 수밖에 없다는 비판이 제기되고 있다.⁵¹⁴⁾ 즉 신탁재산의 물상대위성·독립성·추급효 등은 수익권의 핵심을 이루는 것인데, 이를 신탁법이 특별히 인정한 것이라고 판단한다면 수익권의 내용을 잘못 이해하고 있다는 것이다.

나. 비채권설은 신탁수익자의 채권은 그 유형에 따라 법적 성질이 달라진다고 본다. 그리하여 수익자의 소유권의 유보하고 수탁자에게 용익물권이나 담보물권을 이전하거나 또는 수탁자가 소유권을 갖거나 수익자가 제한물권을 갖는 것과 함께 당사자의 의사해석과 거래상 필요에 따라 그 형태가 정해진다는 견해이다. 그러나 이에 대하여는 과연 이와 같이 여러 형태의 신탁이 신탁법상 인정될 수 있는지 의문이라는 비판이 있으며, 수탁자에게 소유권이, 수익자에게 제한물권이 각 귀속되는 형태의 신탁관계는 물권법정주의에 반하게 되는 문제점이 있다.

다. 물적 권리설은 수익자가 신탁재산의 소유자이고 수탁자에게는 관리할 수 있는 권한이 부여되어 있으나, 다만 법형식상으로는 수익자를 신탁재산의 소유권자로 볼 수 없기 때문에 신탁재산의 특수성에 집중해야 한다는 견해이다. 그리하여 수익자의 권리는 신탁이익의 금부청구권이라는 채권과 함께 신탁재산에 대한 물적 권리도 포함되고, 이러한 물적 권리는 완전권을 외부로부터 제한하는 제한물권의 성질을 갖는 것이며 신탁재산에 포함되는 목적적 제한이 수익자에게 반영되어 형성된 것이라고 한다. 또한 이와 같은 물적 권리는 신탁재산을 대상으로 하는 유한책임에 관한 규정의 근거로 인정되어 있어서 신탁된 재산의 멸실에 대한 위험을 수익자가 부담하고 신탁재산의 물

513) 新井誠, 信託法, 有斐閣(2005), 37.

514) 최동식, 신탁법, 법문사(2006), 57.

적 이동이 수익권 변동으로 포함되며, 따라서 신탁재산과 수익권 사이에 물적 인과관계가 있는바, 이러한 논리는 일본 신탁법 제3조의 공시원칙에 의하여 제3자에 대한 대항력을 갖추게 되므로 일종의 물권적 성질을 갖는다고 한다. 위 물적 권리설에 대하여는 수탁자의 관리권이 신탁재산을 직접 지배하는 것이라면 이는 일종의 물권이라고 할 수 밖에 없기 때문에 물권법정주의에 반하게 되는 문제점이 지적되고 있다.⁵¹⁵⁾ 또한 수익자의 물적 권리의 법적성질이 물권인지, 채권인지 불분명하다는 비판을 받고 있다.⁵¹⁶⁾ 물적 권리설은 신탁관계의 경제적 실질을 정확히 파악한 것이라고 할 수 있지만 법적 구성으로 는 일정한 한계를 가지고 있다는 비판도 제기된다.⁵¹⁷⁾

라. 병존설은 수익권은 채권적·물권적 요소가 병존하기 때문에 이를 분리하는 것은 불가능하다는 견해로서 수익권의 법적 성질을 재산권의 기능적 분해라는 견지에서 논의한다. 이는 재산권의 권능을 관리권능과 수익지배권능으로 나누고 각각 수탁자에게는 관리권능, 수익자에게는 수익지배권능이 있다고 한다.⁵¹⁸⁾ 아울러 수탁자에게 권리명의가 이전되는 것은 관리권능을 부여하였기 때문이며 재산권의 기본이라고 할 수 있는 수익지배권능은 수익권으로서 수익자에게 있고, 종국적으로 수익자에게는 수탁자의 신탁관리를 감독할 권한이 인정되며, 수익에 대한 과세도 수익자에 대하여 하는 것이 당연하다고 한다.⁵¹⁹⁾ 위 병존설에 대하여는 수익권에 채권적 요소와 물권적 요소가 병존한다는 것은 다른 견해에서도 이를 부정하는 것이 아니기 때문에 수익권의 본래 내용을 포기하는 견해라는 비판이 있다.⁵²⁰⁾ 또한 위 견해가 권리의 하위 개념인 권능을 사용하여 관리권능이 수탁자에게, 수익지배권능이 수익자에게 부여되었다고 하지만, 수탁자가 신탁재산을 처분하게 되면 소유권이 제3자에게 이전되는 효과는 단순히 권능으로 포섭하기에는 무리라는 지적도 있다.

2. 신탁수익권의 법적성질에 관한 국내에서의 논의는, 일본의 위 견해들을 이어받

515) 한상근, “부동산 담보신탁의 수익권에 관한 고찰”, 경희법학 제49권 제1호, 경희법학연구소(2014), 7.

516) 물적 권리설은 채권설을 비판하면서 제시된 견해이기 때문에 이를 채권이라고 할 수는 없을 것이고, 이를 물권이라고 한다면 역시 물권법정주의의 문제를 피할 수 없다.

517) 김병일, “신탁법 개정에 따른 신탁세제 개편 방향에 관한 연구”, 조세연구 제10권 제2호,(사)한국조세연구포럼(2010), 314.

518) 坂本 融, “貸貸用不動産の會計處理と稅務”, 稅經通信 6月, 稅務經理協會(2010), 131.

519) 田中 實/山田 昭, 改正信託法(1998), 94.

520) 이중기, “수익권 포기의 개념, 절차 및 비용보상책임에 대한 효과: 신탁종료시의 포기를 중심으로”, [홍익법학 제13권 제1호, 홍익대학교 법학연구소(2012), 699. 이 설은 우리의 신탁법이 일본 신탁법을 모범으로 제정하였고, 일본 신탁법이 채권설에 기반하여 제정되었기 때문에 이를 따를 수밖에 없다고 한다.

아 마찬가지로 채권설,⁵²¹⁾ 물적 권리설,⁵²²⁾ 병존설,⁵²³⁾ 기능설⁵²⁴⁾ 등이 제시되고 있다.

그런데 우리 병존설의 내용은 일본 학설 중 물적 권리설에 유사하다. 즉 수익권은 기본적으로는 수탁자에 대한 채권이지만, 그와 동시에 신탁재산에 대하여 물적 상관관계를 갖는 물적 권리이고, 신탁재산에서 생기는 신탁이익은 모두 수익자가 받으며, 이 권리를 확보하기 위한 방법으로서 수익자의 추급권을 인정하고 있는 점을 고려할 때 수익권의 효력은 채권 이상의 성질을 가지고 있다는 것이다. 그리고 위 기능설은 그 내용이 일본에서의 병존설과 거의 유사하다. 즉 이는 재산권을 물권과 채권으로 나누지 않고 기능상으로 관리권능과 가치지배권능으로 나눈 후 관리권능은 재산권을 관리운영함으로써 가치생산기능을 가지며, 가치지배권능은 그 생산된 가치를 지배하는 기능을 갖는다고 한다. 이처럼 재산권을 기능적으로 관리권능과 가치지배권능으로 나누면 관리권능은 수탁자에게, 가치지배권능은 수익자나 위탁자에게 귀속한다고 보는 설이다. 이에 대하여는 앞서 본 물적 권리설, 병존설의 문제점에 대한 지적과 동일한 비판이 가능할 것이다.

국내의 독특한 견해로는 사원권설⁵²⁵⁾을 들 수 있다. 사원권설은, 신탁은 수탁자의 법적지위가 수익자를 수익하게 할 수 있는 단체적 법률관계의 지위를 갖고 있기 때문에 신탁관계에서 수익자의 지위는 주식회사에서의 사원의 지위와 유사한 법적지위를 획득하고 있다는 견해이다. 이 설은 수익자는 신탁이라는 단체사원으로서 누릴 수 있는 이득을 취하고 조직의 대표권과 업무집행권을 행사하는 수탁자를 감독함과 동시

521) 한상곤(주515), 23.; 김병일, “신탁법 개정에 따른 신탁세제 개편 방향에 관한 연구”, 조세연구 제10권 제2호, (사)한국조세연구포럼(2010), 310-311.

522) 안성포, “유동화에 따른 신탁재산의 독자성에 관한 소고”, 중경법연구 제7권 제2호(2006), 304. 이 설은 신탁계약상의 내용에 따라 일정 급부를 받을 권리가 수탁자에 대한 채권이면서 신탁재산에 대한 물적 상관관계를 갖는 물적 권리라고 하는 견해이다. 신탁재산 구성물의 변동은 수익권의 변동으로부터 기인하기 때문에 신탁재산에서 발생하는 이득을 전부 수익자가 취하게 되며 이러한 이득의 취득에 관한 권리를 확보케 하기 위한 방법으로 추급권이 인정된다고 한다. 이 때문에 물권적 채권적 요소가 연관되어 있는 권리라는 견해도 있다[김상용, “부동산신탁제도의 개관”, 민사법연구(Ⅲ), 법원사(2000), 409.].

523) 장현옥, “부동산신탁에 관한 연구”, 박사학위논문, 연세대학교 대학원(1997. 12.), 125.; 김성필, “신탁법리의 사법의 체계화에 관한 연구”, 박사학위논문, 한양대학교 대학원(1997. 6.), 128. 윤동진, “확률적 접근을 통한 감정평가상 내재한 불확실성의 인식에 관한 연구”, 감정평가학논집 제12권 제2호, 한국감정평가학회(2013), 63. 이 설은 기본적으로 재산권을 관리권능과 가치지배권능으로 나누고 관리권능은 수탁자에게, 가치지배권능은 수익자나 위탁자에게 속한다고 보는 입장이다.

524) 장형룡, 신탁법개론, 육법사(1991), 168.

525) 이중기, 신탁법, 삼우서(2007), 448.

에 신탁재산을 보전하거나 신탁의사를 결정하는 지위를 가진다고 본다. 이러한 사원권 설은 신탁의 단체법적 측면을 부각시킨 독창적이고 논리적인 견해라 할 수 있으나, 우선 신탁을 단체로 보는 전제에 있는데 그 단체의 성격이 무엇인지가 분명하지 않다는 점이 문제로 지적되고 있다. 신탁이 사단이라면 단체의 단독소유, 비법인사단이라면 사원의 총유가 될 것이지만, 신탁법의 규정들만으로 신탁자체에 재산권이 귀속된다고 인정할 만한 근거가 빈약하다. 또한 사단의 사원, 조합원 등 단체의 구성원이 단체대표자가 처분한 재산을 거래 상대방으로부터 반환받는 방법은 대리권 남용의 법리에 의하여야 하고, 이 법리는 대리권을 전제로 하지만, 신탁에서의 수탁자는 어떠한 대리권을 수여받아 신탁이라는 단체의 대리인으로 행위하는 것이 아니며, 나아가 수익자가 1인인 경우와 반대의 경우의 수익권의 성질이 변동되는 것도 설득력이 부족하다.

3. 대법원⁵²⁶⁾은 수익권의 법적 성질과 관련하여, ‘부동산의 신탁에 있어서 신탁자의 위탁에 의하여 수탁자 앞으로 그 소유권이전등기를 경료하게 되면 대내외적으로 소유권이 수탁자에게 완전히 이전되고, 신탁기간의 만료 등 신탁종료의 사유가 발생하더라도, 수탁자가 수익자나 위탁자에게 목적부동산의 소유권을 이전할 의무를 부담하게 됨에 불과할 뿐, 당연히 목적부동산의 소유권이 수익자나 위탁자에게 복귀된다고 볼 수는 없다’고 판시하여, 앞서 본 학설들 중 채권설에 가까운 입장을 보이고 있다.

살피건대, 신탁에서의 수익자의 수익권은 영미법상 대표적인 형평법상의 권리(equitable right)이고, 신탁제도 발달의 초기에는 대인적 권리(이는 우리의 채권과 유사함)가 주된 내용을 이루었으나, 근래에 와서는 대물적 권리(이는 우리의 물권과 유사함)로 인정되고 있다. 일본 또는 우리나라에서 신탁법을 민법체계에 속하는 일종의 특별법으로 제정하면서 민법원리에 충실하게 채권적인 구성을 하였다고 볼 수 있으나, 광의의 수익권에서 인정되는 각종의 물권적 요소(수익자의 추급권 등)를 고려한다면, 수익권은 ‘수탁자에 대한 급부청구권(채권)’을 중심에 두면서 물권적 요소를 갖는 특수한 권리라고 봄이 타당할 것이다.⁵²⁷⁾ 다만 여기서 물권적이라는 것은 수익자가 수탁자 개인의 채권자에 대하여 수탁자 개인의 책임재산으로 되지 않는 것을 주장할 수 있다는 점에서 물권적이라는 것일 뿐, 신탁재산에 대한 직접적인 지배권을 가진다고 하는 의미에서 물권적이라는 것은 아니다.

526) 대법원 1991. 8. 13. 선고 91다12608 판결; 대법원 1994. 10. 14. 선고 93다62119 판결; 대법원 2002. 4. 12. 선고 2000다70460 판결 등

527) 이근영(주490), 197.

이와 같이 볼 경우, 수익권은 기본적으로 수익자가 수탁자에 대하여 갖는 채권적 권리이지만 위 수익권에는 신탁법 제75조 제1항의 수탁자의 신탁위반법률행위의 취소권, 신탁법 제24조의 수탁자 파산시의 환취권 등 완전권적·물권적 성질을 포함하고 있다. 그래서 민법상 채권과는 다른 면이 있기는 하나, 수익권은 본질적으로 금전채권이며 이에 대한 강제집행 시에는 금전채권에 관한 방법으로 강제집행할 수 있다고 보아야 할 것이다.

IV. 신탁수익권에 대한 압류가능성

1. 서

신탁수익권을 기본적으로 채권으로 본다면 이에 대한 압류도 채권에 대한 법리가 적용되므로 압류가 가능할 것이다. 그런데 신탁수익권은 신탁관계라는 특수한 이해관계 사이에서 발생된 권리이기 때문에 채권과 관련된 민사법리를 동일하게 적용시키기 어려운 면이 있는바, 이에 따라 신탁수익권의 특수성으로 인한 압류의 제한 가능성이 문제될 여지가 있다.

여기에서 쟁점은 우선 신탁법 제22조의 강제집행금지규정이 신탁수익권에 대한 집행에 적용되는지 여부이고, 한편 민사집행법리에 의하여 신탁수익권에 대한 집행이 저지될 가능성의 문제는 신탁수익권에 대한 압류가 금지되는지 여부에 관한 것이다. 또한 이와 함께 수탁자와 수익자가 각각 채권자, 채무자인 경우에 수탁자가 수익권을 압류할 수 있는지의 문제도 살펴보아야 한다.

2. 신탁법 제22조 제1항의 강제집행금지 규정의 적용 여부

신탁법은 신탁재산에 대한 강제집행을 금지하고 있다(신탁법 제22조 제1항). 수익권에 대한 강제집행의 결과 신탁목적의 불능이나 해지권의 행사에 의하여 신탁이 종료된 후라면 신탁재산에 대한 강제집행이 적용된 것과 같은 효과가 생기는 경우도 더러 있을 수 있다. 그러나 수익권에 강제집행은 신탁관계의 존속에 직접 영향을 미치는 것은 아니고,⁵²⁸⁾ 수익권에 대한 강제집행으로 인해 신탁재산의 귀속 등에 변동이 생기더라도 이는 신탁법 제22조가 금지하고 있는 신탁재산에 대한 강제집행과는

528) 최현태, “의사결정의 반대수익자를 위한 신탁수익권매수청구권 : 일본 신신탁법의 검토를 중심으로”, 법학논총 제26집 제4호, 한양대학교 법학연구소(2009), 398.

다른 문제이다. 즉 신탁법 제22조의 제정취지는 수익자의 채권자에 의한 신탁재산의 압류만을 금지할 뿐이고 신탁수익권에 대한 강제집행을 금지하는 것으로 이해할 수 없는 것이다.⁵²⁹⁾ 따라서 신탁수익권을 압류가 불가능한 재산권으로 이해하는 것은 옳지 못하며 수익권도 재산권이므로 이에 대한 강제집행은 원칙적으로 가능하고, 그 방법은 수익권에 대하여 추심을 하거나 수익권에 대하여 환가처분(현금화처분) 등을 함으로써 채권을 만족을 얻는 것 등이 될 것이다.⁵³⁰⁾

3. 압류금지 여부

민사집행법상 신탁수익권에 대한 압류금지 여부는 먼저 그것이 성질상 양도가 금지된 채권에 해당될 경우(피압류적격의 문제) 또는 민사집행법 제246조가 정하는 압류금지채권에 해당될 경우일 것이다. 그런데 신탁수익권이 본래 양도⁵³¹⁾가 금지된 다거나 압류금지채권에 해당된다고 보기는 어렵기 때문에 신탁수익권이 특별한 법적 성질을 갖고 있는지 여부를 판단할 필요가 있다.

가. 성질상 양도가 금지된 채권

1) 의의 : 성질상 양도가 금지된 채권이란, ① 국가나 지방자치단체와 같은 공권력 주체만이 행사할 수 있는 공법상의 채권이나 부양료청구권(민법 제979조), 유류분반환청구권(민법 제1115조) 등 일신전속적 권리, ② 상호계산에 편입된 채권(상법 제72조)이나 수임인의 비용선급청구권(민법 제687조)과 같이 그 채권의 목적 내지 성질상 특정한 채권자에게 변제하여야 하는 채권, ③ 종신통기금채권(민법 제725조 이하)과 같이 전적으로 당사자 사이의 개인적 관계에 기초하는 채권으로서 채권자가 달라지면 그 채권의 내용도 달라지므로 채무자의 승낙 없이는 양도하거나 압류할 수 없는 채권을 말한다.⁵³²⁾

529) 한민/박종현, “신탁과 도산법 문제”, BFL 제17호, 서울대학교 금융법센터(2006), 28.

530) 이러한 문제는 입법연혁적으로 신탁법의 입법취지를 되새어 보면 보다 명확해질 수 있다. 일본 신탁법 제정시 참조했던 신탁법 개정 요강안을 살펴보면 수익권에는 당시 일본 민법 제466조 제1항(채권의 양도성)이 적용된다는 것을 밝히고 있으며 이 같은 사실을 통하여 신탁의 수익권에는 이전성과 압류의 가능성이 인정됨을 확인할 수 있다[日本法務省民事局參事官室, 信託法改正要綱試案 補足説明, 法務省(2005), 127.]. 또한 이후의 신탁법 초안에는 수익권의 법적 성질에 대하여 규정하지 않았는데, 이는 채권자대위를 포함한 신탁수익권의 이전성 및 압류의 가능성은 신탁법의 해석상 당연히 인정되는 것으로 이해한 결과라고 볼 수 있다. 이와 같이 현행 신탁법과 동일한 내용인 일본 신탁법의 입법과정을 감안해 볼 때 신탁법 제22조는 수익권에 대하여 압류가 가능하다는 것을 전제로 신탁재산에 대하여 압류를 금지하고 있는 것으로 이해함이 타당할 것이다.

531) 신탁법은 제64조, 제65조에서 신탁수익권의 양도성을 명문으로 인정하고 있다.

532) 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 법원행정처(2014), 298-299.

이와 같은 사항들 중 신탁수익권은 부양료청구권이나 종신통기금채권에 해당될 가능성이 있다.

2) 부양료청구권 : 여기서 말하는 성질상 양도가 금지된 채권으로서의 부양료는 당사자의 계약이나 유언에 의한 부양료를 말한다.

부양료의 지급방식에는 특별한 제한이 없다. 따라서 신탁수익권을 부여하는 방식으로 부양료를 지급하는 것도 가능하다. 수익권의 형태가 반드시 매월 정액을 지급하는 방식이 아니라 하더라도 그 점만으로 부양료에 해당되지 않는다고 할 수는 없다. 부양료인가 아닌가는 그 실질에 의하여 판단되어야 하고, 수익권을 부여하는 형식으로 부양료를 지급한다 하더라도 신탁계약상에 그 취지를 반드시 명백히 기재하여야 한다고 할 수도 없다. 이 경우 피부양자의 수익권은 부양료청구권에 대응하는 신탁수익권이다. 이러한 신탁수익권으로서의 부양료청구권은 피압류적격이 없다.⁵³³⁾

따라서 민법 제974조에 따른 부양료로서의 신탁수익권은 법령에 규정된 부양료로서 민사집행법 제246조 제1항 제1호가 규정하는 압류금지채권이라고 할 수 있다.

3) 종신통기금채권 : 전적으로 당사자간의 개인적 관계에 기초하는 채권의 예로서는 종신통기금채권이 대표적이지만, 위임계약상의 위임자의 채권 등과 같이 다른 형태의 채권이라도 위와 같은 특질을 갖추고 있는 것이라면 마찬가지로 볼 수 있다. 즉 이러한 채권들도 피압류적격이 있다고 보기 어렵다.

특히 민사신탁관계의 수익권은 이러한 성질을 갖는 것이 많을 것이어서 문제가 있다. 예컨대 민법 제725조는 종신통기금을, '당사자 일방이 자기, 상대방 또는 제3자의 종신까지 정기로 금전 기타의 물건을 상대방 또는 제3자에게 지급할 것을 약정한 것'으로 정의하고 있는데, 가족관계에 관련된 신탁은 이러한 성질을 갖는 경우가 많을 것이

533) 수익권에 대해 집행할 수 있는 자는 수익자의 채권자이고, 해당 수익권이 부양료청구권으로 인정되면 집행이 안 되는 것이기는 하지만, 원래 수익자에게 없던 돈이 들어오는 것이므로 수익자의 채권자의 입장에서는 부양료로 인정되는 수익권의 가치가 크더라도 불리하게 되는 것은 아니다. 수익자의 재정상태가 좋아지는 것이므로 반대로 유리한 일이다. 다른 한편 부양료에 대하여는 부양료과다책정의 문제가 있고, 이는 수익자의 채권자들이 아니라 오히려 위탁자의 채권자들에게 있어서 문제가 될 것이다. 이는 신탁 고유의 문제는 아니다. 부양료과다의 문제는 법원이 정한 부양료에 대해서는 일어날 가능성이 낮고 당사자들이 합의에 의하여 정한 경우에는 생길 수 있다. 민법 제978조가 부양을 할 자 또는 부양을 받을 자에게 부양관계의 변경 또는 취소를 법원에 청구할 권한을 인정하고 있으나, 위탁자의 채권자에게는 이러한 권한이 인정되지 않는다. 부양료가 과다책정된 경우 위탁자의 채권자는 채권자취소권을 행사할 수 있다 할 것이다. 한편 수익자가 받는 부양료 명목의 구체제인 수익권이 지나치게 과다할 경우, 수익자의 채권자는 그 과다한 부분에 관해 부양료에 해당하지 않는다는 이유로 집행을 시도할 수도 있을 것이다[임채웅(주483), 287.].

다.⁵³⁴⁾ 민법 제730조는 유증에 의한 종신평기금채권도 가능한 것으로 규정하고 있다.

나. 민사집행법상의 압류금지채권

민사집행법 제246조는 압류금지채권을 규정하고 있는데, 신탁수익권이 본질적으로 압류금지로 되는 경우는 상정하기 어렵고, 신탁수익권이 위 규정의 각 경우에 해당되는 경우 압류금지채권으로 될 가능성이 있다. 또한 이 경우는 민사집행법 제246조 제3항에 따라 수익자의 필요생계비, 자산보유상황 또는 그 밖의 수입상황 등에 의하여 압류금지범위가 변경될 수 있다.

1) 법령에 규정된 부양료(제1항 제1호) : 신탁을 통한 민법 제974조에 따른 부양의 경우에 압류금지채권으로 된다는 것은 위에서 말한 바와 같다.

2) 채무자가 제3자의 도움으로 계속 받는 수입(제1항 제2호) : 조문구조상 위 내용은 '구호사업으로 도움을 받는 수입'에 이어 열거되어 있는 것이므로 구호사업으로 도움을 받는 정도의 내용의 것만 이에 한정된다고 봄이 타당하다.⁵³⁵⁾ 따라서 위 조문에 해당되는 수입은 어느 정도 기간 내로 한정되어야 하고, 비밀상적인 것이 되어야 한다. 그 수준을 넘는 것은 앞서 본 전적으로 개인적 관계에 기초하는 채권에 해당된다고 보아야 한다.⁵³⁶⁾

3) 연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액(제1항 제4호) : 연금이 신탁으로 관리되는 경우(연금신탁),⁵³⁷⁾ 그 수익권은 위 규정에 따라 압류금지채권에 해당될 수 있다. 이 경우는 제1항 제5호의 '퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권'에 해당될 여지도 있다. 신탁수익채권은 그 운용실적에 따라 기간별 금액이 달라질 수 있는바, 위 조문에서의 2분의 1은 현실화된 금액의 2분의 1로 해석해야 할 것이다.

534) 예를 들어 위탁자(甲)가 자신의 생존 중에는 위탁자 자신이, 사망 후에는 처인 乙이, 乙의 사망 후에는 그 아들인 丙이 성년이 될 때까지 각 수익자가 되는 신탁을 설정한 경우, 위 신탁에서 위탁자 생존 중에는 위탁자 자신이 수익자가 되므로 문제될 것이 없으나, 처인 乙의 수익권은 그 실질이 종신평기금과 동일하다. 결국 이 문제도 실질적인 비교를 하여 종신평기금적인 성질을 갖는 것은 집행대상에서 제외된다고 할 수밖에 없다. 이러한 경우, 위탁자의 채권자는 사해행위 또는 사해신탁 취소의 문제로 대처하는 수밖에 없고, 수익자의 채권자는 수익권에 대해 집행하지 못한다는 결과로 된다.

535) 임채웅(주483), 289.

536) 임채웅(주483), 289.

537) 통상 연금신탁은 개인의 노후생활보장 등을 위하여 일정기간동안 일정액을 정기적으로 적립하거나 일시에 신탁한 후 일정기간이 도래하였을 때 신탁원리금을 일시에 또는 일정기간 동안 정기적으로 지급받는 금전신탁을 말한다. 이는 대체로 생계형 신탁계약에 의한 것으로서 신탁의 목적과 수익권의 요건에서 압류금지채권에 해당될 가능성이 있다.

그런데 실무상 상업적 목적으로 설정되는 신탁의 경우 이는 대부분 이자를 목적으로 하는바 이때는 압류금지채권에 해당될 가능성이 높지는 않다.⁵³⁸⁾ 연금신탁의 경우에도 수익자는 위탁자 본인 또는 위탁자가 지정하는 1인의 개인이 될 수 있으며, 대개의 경우는 위탁자 본인이 수익자가 되는 자익신탁이고 또한 다른 신탁과 마찬가지로 이자를 목적으로 하는 성격이 강하다.⁵³⁹⁾ 그래서 민사집행법이 정하고 있는 압류금지채권에 해당한다고 보기는 어려우나, 다만 연금신탁이 수익자를 제3자로 하는 타익신탁의 형태로 되는 때의 신탁수익권은 민사집행법 제246조 제1항 제2호에서 정하는 제3자의 도움으로 계속 받는 수입에 해당되어 압류금지채권으로 될 가능성이 있다.

이와 같이 상업적 목적으로 체결되는 신탁계약 중에서는 연금신탁이 타익신탁으로 설정될 때에 압류금지채권에 해당될 가능성이 있을 뿐이나, 우리의 경우에도 노령화사회가 시작되고 있고, 이에 대한 노후생활 대책으로서 개인들의 노력에 의한 연금신탁 등의 기능이 활성화 될 수 있으므로, 이러한 연금신탁은 그 취지 등으로 보아 모두 압류금지채권에 포함시킬 필요가 있다. 향후 이에 대한 법적인 근거 등이 필요할 것이다.

4. 수탁자의 압류가능성

가. 원래 채무자는 채권자의 자신에 대한 채권을 당연히 압류할 수 있다. 즉 채무자는 자신의 별도의 채권을 확보하기 위하여 자신을 제3채무자로 한 압류를 할 수 있음이 원칙이다. 신탁관계에 이러한 점을 대입해보면 수탁자도 수익권에 대해 압류할 수 있다 할 것인데, 수탁자는 수익자에 대한 단순한 채무자가 아니며 그 이상의 높은 정도의 의무(충실의무)를 지는 자라는 점에서 이와 달리 보아야 하지 않는가 하는 점이 문제된다. 통상 수탁자는 은행을 비롯한 금융기관인 경우가 많고, 따라서 수탁자는 신탁관계와 별도로 수익자와 금융거래를 하는 경우가 상당히 많다. 그 필연적인 귀결로, 수탁자가 자신이 수탁자로서의 의무를 지는 수익권에 대해 집행할 수 있는지가 문제될 수 있는 것이다.

또한 양도가능한 신탁수익권은 당연히 담보물이 될 수 있고, 이에 대하여는 통상 권리질권이 설정될 수 있을 것이나, 수익자의 채권자인 수탁자가 수익권에 대한 질권을 취득할 수 있는지 여부에 관하여는 견해가 나뉘고 있고, 이는 위 압류가능성의 문제와도 연관이 있으므로 함께 살펴볼 필요가 있다.

538) 정영석, “금전채권에 대한 강제집행”, 주택금융월보 2009년 3월호, 한국주택금융공사(2009), 43.

539) 신탁전문위원회/전국은행연합회, “은행신탁거래표준약관(노후생활연금신탁약관)”, 전국은행연합회(1998), 19.

나. 우선 일본 판례 중에는 日大判 昭和 8(1933). 3. 14.(民集 12, 350)이, “신탁회사가 자기에 대한 수익자의 수익권에 대하여 다른 채권을 위하여 질권을 취득하는 것은 신탁법 제9조, 제22조⁵⁴⁰⁾의 규정에 저촉하는 것이 아니며 유효하다.”라고 판시하여 질권의 설정 가능성을 인정하는 취지로 판시하고 있다. 또한 우리 대법원 2005. 6. 10. 선고 2004다42296 판결은 수탁자가 자신이 수탁자인 수익권으로 하여 질권을 설정받은 사안에서 그것이 당연히 유효하다는 전제하에서 판단을 하고 있다. 다만 그 유효성에 관하여 정면으로 다루고 있는 것은 아니어서 과연 이를 신탁법리의 차원에서 명확한 검토를 한 것인지 명확하지 않다.

다. 이 문제에 관하여 집행법상의 법리상으로 별다른 제약은 발견되지 않는다. 따라서 신탁법상의 특유한 법리, 즉 수탁자의 충실의무 등이 이에 대하여 적용되느냐 하는 것이 쟁점이라고 할 것인데, 여기서 검토되어야 할 조문은 신탁법 제34조에서 정하는 이익에 반하는 행위의 금지와 제36조에서 정하는 수탁자의 이익향수금지에 관한 규정이 될 것이다. 위에서 질권 취득을 허용한 위 일본판례의 취지는, 질권 취득이 위 조문상의 제한에 해당되지 않는다고 보는 것이라 하겠다.

이에 대하여 적극적으로 해석하는 견해(적극설)가 있다.⁵⁴¹⁾ 즉 신탁재산과 수익권은 별개이고 수탁자가 수익권에 대해 질권을 설정하는 것은 신탁재산에 대해 권리를 취득하는 것이 아니므로 그것이 가능하다고 보는 것이다.

그러나 신탁재산과 수익권이 별개의 것이라고 하더라도 수탁자가 수익권의 질권자가 되거나 압류가능한 채권자가 된다면 이는 결과적으로 신탁재산에 대한 지배권을 갖는다고 보아야 하고, 이는 위 신탁법의 규정에 반한다고 보지 않을 수 없다. 그렇다면 수탁자가 민사집행의 방식이나 그 밖의 다른 방법으로라도 수익권 자체를 취득하는 것은 허용되지 않는다고 보아야 한다. 수탁자 자신이 집행을 하여서도 불가능하고, 제3자의 집행으로 이루어진 매각절차에서 수탁자가 매수하는 것도 불가능하다고 보는 것이 타당하다.⁵⁴²⁾ 따라서 구체화된 수익권에 대하여 전부명령이나 추심명령을 얻는 것도 충실의무와 충돌할 우려가 있으므로 허용되어서는 안 될 것이다. 다만 수탁자가 자신이 수탁자인 신탁관계의 수익권(기본적인 수익권)에 관하여 그 수익권을 압류한 후 매각명령을 얻어 자신의 채권을 회수하는 것은 가능할 것이다.⁵⁴³⁾ 이는

540) 이는 일본의 구신탁법 조문으로서, 현재 우리의 신탁법 제34조, 제36조에 해당한다고 볼 수 있다.

541) 신종진, “신탁수익권의 강제집행방법”, 조사월보 420, 한국산업은행(1990. 11.), 41.

542) 임채웅(주483), 301.

543) 임채웅(주483), 301.

을 이유가 없다. 이와 마찬가지로 위탁자와 수익자가 동일인이라고 하여 달라져야 할 이유가 없다. 위 견해는 위탁자가 여전히 지시권을 행사함으로써 신탁재산, 나아가 수익권에 해를 끼칠 우려가 있다는 생각을 염두에 두고 있는 듯하지만, 이는 반드시 그렇다고 하기 어렵다.⁵⁶⁹⁾ 위탁자의 지시권은 수익권과 관련은 있으나 엄연히 별개의 것이고, 수익권에 대한 압류에 의하여 영향을 받는다고 보기 어렵다. 또한 위탁자가 압류채권자의 승낙을 얻어 지시권을 행사한다는 것도 비현실적이라고 할 수 있다. 간 이한 신탁의 경우에도 그것이 결코 쉽지 않을 것이며, 관계인이 다수인 상신탁의 경우를 생각해보면 더욱 그러하다.

따라서 수익권에 대한 압류에 의하여 위탁자의 지시권이 영향을 받을 이유는 없으므로, 위탁자의 지시권 행사가 부당하다면, 압류채권자는 가처분 등에 의하여 대처하는 수밖에 없다. 자익신탁의 경우에는 위탁자가 수익자의 지위도 겸하고 있으므로, 지시권을 부당하게 행사하는 경우 채권자의 채권을 침해 하는 행위로 불법행위 등의 책임을 물을 수 있을 것이다.⁵⁷⁰⁾

569) 위탁자의 입장에서는 신탁재산이 잘 관리되어 압류권자의 채권을 변제하고도 남는 것이 있어야 유리한 것이다. 또한 그 반대로 위탁자의 입장에서는 압류 이후에는 실질적으로 자신의 이해관계가 없다고 생각하여 신탁재산에 대한 지시권 행사에 무관심해질 우려도 있다.

570) 임채웅(주483), 292.

있는 것이지만 실질과 내용은 주권과 유사하므로 유가증권의 집행방법 중 주권의 집행방법에 따라 처리하여야 할 것이다.⁵⁶⁷⁾

6. 특정금전신탁에서의 위탁자의 지시권

가. 특정금전신탁은 위탁자가 신탁재산의 운용방법을 특정하는 금전신탁으로서 수탁자는 위탁자가 지정한 방법대로 자산을 운용하여야 하고 다른 신탁상품과는 합동 운용할 수 없으며 원본 보전과 이익 보족이 금지되어 있는 반면, 불특정금전신탁은 위탁자가 신탁재산의 운용방법을 특정하지 않고 수탁자에게 일임하는 금전신탁으로서 수탁자는 관계 법령에서 정하고 있는 방법과 대상의 제한 범위 내에서 자유롭게 자산 운용을 하고 다른 신탁상품과도 합동운용할 수 있으며 관계 법령이 정하는 바에 따라 원본 보전과 이익 보족(補足)이 허용된다.

특정금전신탁은 위탁자가 지정한 운용방법에 따른 자산운용에 의하여 그 수익률이 변동함으로써 항상 위험이 따르고, 그 위험은 신탁회사가 신탁재산에 대하여 선풍한 관리자로서의 주의의무를 다하지 아니하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 수익자가 부담하여야 하므로, 그 신탁재산의 운용 결과에 대한 손익은 모두 수익자에게 귀속되는 자기책임주의와 실적배당주의를 그 본질로 하고 있다.

나. 이와 같이 특정금전신탁의 경우 위탁자가 상당한 정도의 지시권을 갖게 되는 데, 만일 수익권이 압류되는 경우에 위탁자가 지시권을 계속하여 행사할 수 있는지 여부가 문제된다.

이에 대하여 수익권의 압류에 의하여 위탁자의 지시권은 정지되며, 압류채권자의 승낙을 얻어 위탁자의 지시권 행사를 인정하는 것이 바람직하다는 견해가 있다.⁵⁶⁸⁾ 이 견해는 수익권의 압류에 의하여 채무자측의 신탁재산에 대한 관여권이 정지된다고 보는 것인데, 특히 자익신탁의 경우 수익권이 압류되었음에도 수익자이며 동시에 위탁자인 채무자가 계속하여 그 수익권에 영향을 미치는 행위를 하는 것이 부당하다는 생각이 근저에 깔려 있는 것으로 보인다.

그러나 위탁자의 지시권은 수익권의 내용이 아니다. 위탁자와 수익자가 다른 사람인 경우를 생각해 보면, 수익자의 수익권이 압류되었다고 하여 위탁자가 영향을 받

567) 한상곤(주515), 27.

568) 신종신(주541), 46.; 中央信託銀行信託研究會, “信託受益權と強制執行(下)”, 金融法務事情 No.1257(1990. 6. 25.), 25.

상으로 삼기 어려운 것일 경우에만 그러한 점을 들어 이를 불허하는 것으로 보는 한 정적 적극설이 타당하다고 본다.

다. 수익증권에 대한 집행

1) 신탁법 제78조 제1항은 신탁행위로 수익권을 표시하는 수익증권을 발행하는 뜻을 정할 수 있다고 규정하고 있다.

신탁법상의 위 수익증권은 주식회사에 있어 주권과 유사하다.⁵⁶²⁾ 주식회사의 주권은 주주의 여러 가지 공익권과 자익권을 표상하는 유가증권이며 수익증권 역시 현행 신탁법의 내용상 신탁관계에 있어 수익자의 여러 권리를 포함하고 있기 때문이다. 따라서 수익증권은 기본적인 수익권을 화체하고 있는 유가증권으로 보는 것이 타당하다.⁵⁶³⁾ 신탁법상 수익증권을 발행할 경우에는 수익증권의 종류·수익자명부제도·수익증권발행에 대한 규제·수익증권 양도와 수익자명부예의 명의개서·수익증권 권리 추정력·수익자명부 권리추정력 등에 관한 규정을 준수하여야 한다. 이는 상법상 주식회사의 주권, 주주명부 등에 관한 규정과 유사한 규정을 둔 것이다.⁵⁶⁴⁾ 수익자의 입장에서 보면 수익증권을 통해 신탁재산의 운용에 관하여 수익을 얻는 것이며, 이로 인한 책임은 수익권의 상실을 한도로 하는 것이기 때문에 일종의 책임제한효과를 얻을 수 있다. 신탁법상의 수익증권은 회사의 주주의 권리와 비교되며 법제도로써 어느 정도는 경쟁관계에 있다고 할 것이다.⁵⁶⁵⁾

2) 민사집행의 책임재산이 기본적인 수익권이고 신탁법상의 수익증권이 발행된 신탁의 경우라면 수익증권에 대한 집행으로 처리하여야 한다.⁵⁶⁶⁾ 신탁법상 신탁에서 수익증권이 발행되어 있는 경우 수익자가 채권자에게 입질하거나 채권자가 집행권원을 얻어 집행할 수 있다. 수익증권의 내용이 실질적으로 기본적인 수익권을 화체하고

명의 유무효가 핵심쟁점은 아니었고, 따라서 위 판례들을 두고 우리나라의 판례가 신탁수익권에 대한 전부명령을 허용하고 있다고 단정하기에는 부족하다. 그러나 신탁관계를 명확히 인식하지 못하는 입장이 통용되어 왔다는 것은 이를 달리 보면 신탁의 본질을 해하지 않는 한 금전급부를 내용으로 하는 신탁수익권을 일반금전채권에 준하여 취급해도 무리가 없다는 것이고, 따라서 전부명령의 대상으로 한다고 하여 크게 불합리하지 않다는 점을 보여주는 것이라 하겠다.

562) 안성포, “유동화에 따른 신탁재산의 독자성에 관한 소고”, 증권법연구 제7권 제2호, 2006, 295.

563) 企業會計基準委員會, “信託の會計處理に關する實務上の取扱い”, 實務対応報告第 23号, 企業會計基準委員會(2007), 9.

564) 법원행정처, 신탁법 개정을 위한 입법자료, 법원행정처(2009), 214.

565) 김은집/김용호/남재현, “수익증권발생택 관련 자본시장법상 제문제”, 선진상사법률관계 제59호, 법무부(2012), 224.

566) 임재웅(주483), 289.

나, 대체로 권면액에 대한 언급없이 위 장래의 채권, 조건부채권, 반대급부에 걸린 채권의 대부분에 관하여 전부명령을 허용하고 있다.⁵⁵⁹⁾

기본적인 수익권의 경우는 현재 확정적으로 발생한 권리이지만, 위에서 요구하는 권면액이 없다고 봄이 맞을 것이다. 따라서 비록 현재에도 가치가 있기는 하나, 그 가치는 실가이지 권면액이 아니다. 장래 얼마 정도의 금액으로 확정될 수 있을지 알 수 없는 상태인 것이다. 따라서 이 경우의 신탁수익권은 마치 부동산이전등기청구권 등의 채권과 같은 방법으로 현금화하는 것이 상당할 것이다. 그러나 이러한 일반론이 장래 확정될 구체화된 수익권에 대해서도 타당한지는 의문이다. 특히 상사신탁이나 영업신탁의 경우 상당한 공신력을 갖춘 신탁회사가 수탁자가 되는 관계로 극단적인 경우가 아니면 수익권의 가치가 영(零)이 되는 경우는 거의 없다고 해도 과언이 아니다. 게다가 상당히 많은 경우 실질적으로 정기이자를 지급하는 형태로 수익권이 실현되고 있고, 당사자들 또한 일반 예금처럼 인식하고 있는 경우가 많다. 즉 현실적으로 전부명령을 내려도 크게 부당하지 않고 결과적으로도 채권자의 채권이 만족을 얻을 수 있는 경우에 대하여까지 권면액이 요구된다는 이유로 전부명령을 허용하지 않을 필요는 없다.⁵⁶⁰⁾ 장래의 확정되지 않은 구체화된 수익권은 기한부채권도 아니고 조건부채권도 아닌 아직 그 구체적인 금액조차 확정되지 않은 채권이고, 장래에 채권액이 없을 수 있는 것인지는 채권 자체가 아니라 신탁의 운영에 대한 전문적인 수익성 검토가 필요하다. 따라서 위 견해들 중 전부명령의 가능성을 개별적인 신탁 수익권 별로 판단해 보아 잔여재산에 대한 권리 또는 구체화된 수익권으로서 금전으로 표시되는 것에 대하여는 허용하되,⁵⁶¹⁾ 특별한 사정이 있어 수익권의 내용이 전부명령의 대

559) 대법원 1965. 4. 27. 선고 65다142 판결; 대법원 1976. 2. 24. 선고 75다1596 판결; 대법원 1977. 9. 28. 선고 77다1137 판결; 대법원 2002. 11. 18. 선고 2002다7527 판결 등

560) 수익권의 내용이, 「신탁재산의 운용에서 얻은 이익 중 수익자에게 매월말일 금 200만원을 지급하고, 나머지 금액은 신탁재산에 편입한다.」라고 하는 경우에도 이는 실질적으로 권면액이 있는 것과 다름없다고 볼 수 있다. 이 경우에도 실적배당주의에 의하여 운용이 원활하지 않았던 결과 수익자가 받을 돈이 월 200만원을 밑도는 경우가 있을 수 있으나, 그것은 권면액이 확정된 채권이지만 채권내용대로 지급되지 않는 경우와 다를 바 없는 것이다.

561) 대법원 1999. 10. 6.자 99마4857 결정; 광주지방법원 1993. 11. 10. 선고 93가합106 판결 등 참조. 위 광주지법판결은 채권자가 제3채무자(은행)에 관하여 '채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 예금채권 중 0원'이라고 되어 있어 채권예금이나 예금종류가 특정되지 않았고 전부명령상 채무자의 주소와 예금계약상 채무자의 주소가 달랐으며, 채무자가 제3채무자에 대하여 다른 예금을 가지고 있지 않다면 제3채무자로서는 전부명령의 기재상 채무자가 제3채무자에 대하여 가지고 있는 예금반환청구채권이 전부되었음을 용이하게 알 수 있으므로 전부명령은 유효하다고 하였다. 이 경우 그 존재하는 채권이 '기업금전신탁금'이었다. 위 대법원판결 등에서의 집행대상은 장래에 정기적으로 지급될 구체화된 수익금이 아니고, 기본적인 수익권에 가까운 것이라고 할 수 있다. 위 두 사건에서 사건당사자들은 물론이고 법원도 신탁관계에 대해 특별히 인식하였던 것 같지는 않고, 일반예금 정도로 취급하였던 것으로 보인다. 즉 위 두 사건 모두 신탁수익권에 관한 전부명

득하는 방안을 모색하여야 하며, 추심명령이 불가하므로 수익권 전부에 대해 매각명령을 얻은 다음 매수를 하거나 양도명령에 따라 양도받아야 할 것이다.⁵⁵³⁾

나) 전부명령의 허용여부

구체화된 수익권을 크게 두 가지로 분류하자면 이미 이행기가 도래하여 특정금액을 지급할 것이 예정된 구체화된 수익권과 장래에 변제기가 도래하여 장래에 금액이 확정될 구체화된 수익권으로 구분해 볼 수 있다. 이미 이행기를 도래한 구체화된 수익권은 액면가가 정해진 금전채권이기 때문에 일반적인 금전채권과 동일할 것이며 집행에 있어 금전채권의 경우를 따르면 될 것이다.⁵⁵⁴⁾

아직 이행기가 도래하지 않은 구체화된 금전채권의 경우는 문제이다. 신탁계약상 수탁자의 수익자에 대한 정기적인 급부가 있도록 규정한 경우 급부액에 대한 일정액이 정하여져 있다면 일반적인 이행기가 확정된 장래의 금전채권에 해당할 것이나, 신탁은 실적배당주의가 원칙이므로 장래의 급부액 또는 수익권의 가치가 미확정인 경우가 많을 것이다.⁵⁵⁵⁾ 따라서 이 문제는 가치가 확정되어 있지 아니한 채권은 전부명령의 대상이 될 수 없는가 하는 것과 동일선상에 있는 것이라고 볼 수 있다.

실무상 이에 관하여는, 이 경우 수익권의 가치가 미확정상태이므로 전부명령이 불가하다는 견해(소극설)⁵⁵⁶⁾와 기본적인 수익권 자체에 대하여는 허용될 수 없지만 잔여재산에 대한 권리 또는 구체화된 수익권으로서 금전으로 표시되는 것에 대하여는 허용하되, 특별한 사정이 있어 수익권의 내용이 전부명령의 대상으로 삼기 어려운 것일 경우에만 그러한 점을 들어 이를 불허함이 타당하다는 견해(한정적 적극설)⁵⁵⁷⁾가 나타나고 있다. 소극설은 전부명령을 위해서는 권면액이 필요하다는 원칙적인 입장에 충실한 견해라고 볼 수 있다.

그런데 일반적으로 전부명령의 대상이 되려면 권면액을 가질 것이 요구되고 있으나, 금전채권 중 장래의 채권·조건부채권·반대급부에 걸린 채권 등과 같이 채권의 확정적 실현이 의문시되어 권면액의 존재를 인정하기 어려운 채권에 대하여도 그것이 전부명령의 대상이 될 수 있는가에 관하여 부정설과 긍정설이 나뉘고 있다. 판례 중에는 전부명령의 요건으로서 권면액의 존재가 필요하다는 입장을 취한 것⁵⁵⁸⁾도 있으

553) 임채웅(주483), 299.

554) 최수정(주501), 148.

555) 최수정(주501), 154.

556) 신종신(주541), 51.

557) 임채웅(주483), 297-298.

558) 대법원 1973. 1. 24.자 72마1548 결정

가) 추심채권자의 신탁해지 청구가능여부

금전급부를 내용으로 하는 장래에 확정될 구체화된 수익권에 대하여는 추심명령이 가능할 것이다. 다만 이 경우 수익권을 압류·추심한 채권자가 그 추심권의 행사로 신탁을 해지할 수 있는지 여부가 문제된다.

이에 관하여 타익신탁에서는 안 되지만 자익신탁에서는 허용되어야 한다는 견해가 있다.⁵⁴⁸⁾ 위 견해는 신탁계약상 약정이 있다면 수익자의 채권자도 당연히 해지할 수 있고 자익신탁의 경우에도 신탁해지권은 신탁법 제99조 제2항의 위탁자의 권리이며 수익권의 압류채권자는 위탁자가 아닌 수익자의 지위를 대위하는 것인바 위탁자가 수익자의 지위를 동시에 가지는 자익신탁의 경우에는 그 특성상 해지권을 인정할 수 있다는 것이다.

추심명령의 일반법리에 따르면, 추심채권자가 해제권·취소권을 행사할 수 있다고 보는 것이 통설이고,⁵⁴⁹⁾ 판례⁵⁵⁰⁾의 경우도 보험계약환급금청구권에 대한 추심명령을 얻은 채권자가 추심명령에 기하여 제3채무자를 상대로 추심금의 지급을 구하는 소를 제기한 사안에서 ‘이 경우 그 소장에는 추심권에 기초한 보험계약 해지의 의사가 담겨있다고 할 것이므로, 그 소장 부분이 상대방인 보험자에 송달됨에 따라 보험계약 해지의 효가 발생하는 것으로 해석함이 상당하다’고 판시하고 있다.

그러나 신탁수익권에 대하여 추심명령을 얻어 해지하려면 당연히 수익권 전체에 관하여 추심명령을 얻어야 한다. 그런데 신탁관계는 위탁자, 수탁자 및 수익자의 관계가 단순히 금전을 대여하고 차용하는 관계 등과는 달리 고도의 신뢰관계를 바탕으로 하여 결합된 법률관계라 할 수 있으므로 추심권을 얻은 것만으로는 해지할 수 없다고 보는 것이 타당하다.⁵⁵¹⁾ 즉 그 중 기본적인 수익권에 대해서는 추심명령이 허용될 수 없고, 귀속재산에 대한 권리나 구체화된 수익권 중 금전급부를 내용으로 하는 것만 추심이 가능할 것인데, 그러한 권리는 전체 수익권의 일부에 불과한바, 권리의 일부에 대해서만 추심명령을 얻은 자가 계약관계 전체의 해제(해지)나 취소를 할 수는 없다 할 것이다.⁵⁵²⁾

따라서 신탁의 해지까지 염두에 두고 있는 채권자는 기본적인 수익권 전체를 취

548) 신종신(주541), 47.; 中央信託銀行信託研究會, “信託受益權と強制執行(下)”, 金融法務事情 No.1257(1990, 6, 25.), 26.

549) 손진홍, “추심명령에 관한 제문제”, 재판실무연구(2) 민사집행소송, 한국사법행정학회(2007), 515. 이하

550) 대법원 2009, 6, 23. 선고 2007다26165 판결

551) 임재웅(주483), 298-299.

552) 이는 마치 일반적인 매매계약에서 부종된 급부의무를 개별적으로 해지할 수 없는 것과 같은 논리라고 볼 수 있다.

면서 그 기준시점을 앞당겨 「위탁자 甲, 수탁자 乙, 수익자 丙인 ○○○신탁계약에 의하여 수익자 丙이 수탁자 乙로부터 2019. 5. 1.부터 매월 말일 받을 금 200만원의 채권으로 청구채권 금 2000만원에 이르는 금액」과 같이 압류를 신청하였다면 2019. 5. 1. 이후의 것으로 이미 발생한 부분에 대한 압류도 함께 신청한 것으로 이해하여야 한다.

나. 구체적인 집행방법

1) 기본적인 수익권

기본적인 수익권의 내용은 다양하다. 가령 그 내용이 모두 금전의 급부에 관한 것이라 하더라도 그러한 기본적인 수익권이 곧 금전채권이라 할 수도 없고, 구체화된 수익권이 금전급부를 내용으로 하는 경우에도 기본적인 수익권 자체가 금전채권이라 할 수도 없다. 신탁재산이 부동산이라 하여 그 수익권이 민사집행법리에서 말하는 부동산에 대한 권리라 할 수도 없다. 또한 위와 같은 이유로 수익권은 유체물인도청구권이라 할 수도 없고, 유체동산에 대한 청구권이라 할 수도 없다. 수익권은 채권임에도 불구하고 신탁관계의 수익자로서의 지위에서 갖는 전 권리의 집합체로서 재산의 교부를 청구하는 권리 이상의 내용을 갖추고 있다.⁵⁴⁵⁾

결국 수익권, 특히 기본적인 수익권은 민사집행법 제251조에서 말하는 ‘그 밖의 재산권’이라 볼 수밖에 없고,⁵⁴⁶⁾ 그 밖의 재산권에 대해서도 만일 그 성질이 허용하면 추심명령이나 압류명령 등이 가능할 것이나, 기본적인 수익권은 본질적으로 그에 해당될 가능성이 없다 할 것이다. 따라서 보통의 신탁에 있어서는 민사집행법 제241조의 특별한 현금화방법에 따라 수밖에 없다.⁵⁴⁷⁾

2) 구체화된 수익권

구체화된 수익권의 내용도 다양할 수 있고, 이에 대하여는 앞의 기본적인 수익권에 관한 설명이 그대로 적용될 수 있다. 다만 그것이 외형상 일반적인 금전채권의 형태를 띠는 경우에는 다른 가능성을 모색해볼 수 있다. 압류시점에 이미 구체화된 수익권으로 금전에 관한 것은 일반 금전채권과 같은 방법으로 집행할 수 있으므로 검토 대상에서 제외하고, 여기서는 금전급부를 내용으로 하는 장래에 확정될 구체화된 수익권에 관하여 보기로 한다.

545) 최현태(주528), 397.

546) 中央信託銀行信託研究會, “信託受益權と強制執行(下)”, 金融法務事情 No.1257(1990. 6. 25.), 24.

547) 임채웅(주483), 293.

신탁재산의 지배권과 관계가 없기 때문이다.

5. 집행방법

가. 특정과 표시의 문제

수익권은 통상 그 성격을 채권으로 인식하고 있으므로, 그 집행은 원칙적으로 채권집행방법에 따라야 할 것이다.

수익권 중 기본적인 수익권은 그 실질가치가 시점에 따라 계속 증감된다고 하더라도 현재 확정된 권리이다. 이와 달리 장래에 특정한 방식으로 지급될 구체화된 수익권은 장래의 채권으로서의 성격을 띠고 있다. 따라서 아직 구체화되지 않은 장래의 구체화된 수익권을 압류하는 것은 장래에 발생할 채권을 압류하는 것이 된다.

이미 지급시기를 초과하여 구체화된 채권은 위와 같은 채권과 약간 성격을 달리한다. 압류 이전에 그 구체화된 채권이 변제되었다면(수익자가 수령하였다면) 더 이상 압류가 문제되지 않고, 아직 변제되지 않았다면 압류의 대상이 될 것이나, 이는 수익권에 터잡아 발생한 구체화된 금전채권을 압류하는 것이지 원래의 의미에서 수익권을 압류하는 것이라 하기 어렵다.

그러므로 수익권을 압류함에 있어서는 압류대상채권의 표시 등에 상당한 주의를 기울여야 한다. 그리하여 만일 「○○○수익권을 금 ○○○원 한도에서 압류한다」는 결정이 내려진 경우, 기본적인 수익권을 압류하는 취지로 이해하여야 할 것이다.⁵⁴⁴⁾ 기본적인 수익권에는 구체화된 수익권도 포함되는 것으로 볼 수 있으나, 구체화된 수익권에 관해서는 그 결정의 효력이 발생된 때 이후 몫에 대하여 압류한 것으로 보아야 한다. 그 결정의 효력발생 전에 이미 구체화된 부분은 수익권에 터잡아 수익자가 취득한 권리이기는 하지만 수익권 그 자체라고 할 수 없으므로, 별도로 표시하여 압류하여야 할 것이다. 예컨대 앞의 예에서 2019. 10. 1.에 압류를 신청하

544) 이 경우 위 압류의 효력은 신탁재산 자체에는 미치지 않는다고 해석해야 한다. 신탁재산 자체에 대한 집행은 신탁법 제22조에 따라 금지된다. 수익권이 실질적으로 신탁재산에 터잡은 권리이고, 수익자가 수익권을 취득함으로써 신탁재산에 대한 귀속자로서의 권리까지 취득한다고 하더라도(수익자가 반드시 그러한 권리를 보유하여야 하는 것은 아니다), 신탁재산 자체가 수익권의 일부에 포함된다고 할 수는 없다. 이러한 논리는 수익권의 내용에 원본에 대한 것이 포함된다고 하더라도 마찬가지이다. 따라서 예를 들어 위탁자가 수탁자에게 금 1억 원을 교부하고 그 수익에 의해 수탁자가 수익자에게 월 200만원씩 지급하기로 하는 신탁과 관련하여 수익자의 채권자가 「...수익권을 금 5천만 원의 한도에서 압류한다」는 결정을 얻은 경우에도, 신탁재산에 해당하는 원본 1억 원에 대해서는 압류효과는 미치지 않는다고 보아야 한다.